

跨越國境的勞動平權？^{*} ——論勞動權利之平等保護面對 「暫時性跨國移工制度」之侷限

楊雅雯^{**}

摘要

本文以臺灣之暫時性藍領移工為例，分析移工制度何以是國際勞動平權保護的難題。蓋跨國移工既是勞工也是外國人，本於勞工身分，其理應享有不受差別待遇之勞動條件；但使之居於弱勢的核心法律機制，卻是其外國人身分，因為國家對外國人的跨國移動享有廣泛國境管控權力，得設定其入境、居留條件以保護內國勞動市場，但國際人權法原則上不介入國境管制。因此，當暫時性移工制度的主要特徵，是由會傷害移工勞動條件的國境管控組成，則人權法究應堅持勞動權利平等，抑或應著重在對國境管制之退讓，其張力即難以化解。本文先詳析勞動平權之規範架構，再藉由我國4項移工制度設計（強制定期契約、健康檢查、轉職禁止與居住行方控制），具體分析國境管制如何傷害移工勞動條件，卻不易被界定為勞動條件之差別待遇，並提出國境管制與勞動保護之衡平為未來之方向。

關鍵詞：移工、外籍勞工、就業權利、勞動條件之權利、平等保護、經濟、社會及文化權利國際公約、國際勞動組織、國境管制。

* 投稿日：2020年3月2日；接受刊登日：2020年9月9日。〔責任校對：陳怡瑾、黃品瑜〕。

作者感謝二位匿名審稿人與李柏翰博士之評論建議。

** 中央研究院法律學研究所博士後研究學者。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/82411012.pdf>。



目次

壹、前言：研究問題與範圍	肆、國境控管對移工勞動條件之效應
貳、外國人勞動權利平等保護之確立與退讓	一、強制定期契約：永久臨時工
一、外國人平等勞動權利之確立	二、健康檢查：國境對移工之健康監理
二、外國人平等勞動權利之退讓	三、禁止轉職：不自由的勞動力
參、臺灣「暫時性移工制度」之設立與運作邏輯	四、居住與行方控制：私人化的國境管制權力
一、制度背景與政策目標	伍、結論
二、移工跨國流動之文書控管	

「整個移民與公民權的領域，預設了將人分成兩類的正當性：一邊是公民，另一邊不是，而這個差別必須有意義¹。」

壹、前言：研究問題與範圍

臺灣對暫時性跨國移工之官方政策，至少自2000年以來，於「移工權益維護報告書」中所述之立場，向來強調「工作權益上之國民待遇原則」²。報告書引用世界人權宣言第7條規定「法律之前人人平等，並有權享受法律的平等保護，不受任何歧視」，隨即指出：

故外籍勞工在臺工作，當受我國勞工相關法令保障。如為

¹ Hiroshi Motomura, *The Rule of Law in Immigration Law*, 15 TULSA J. COMP. & INT'L L. 139, 141 (2008).

² 勞動部勞力發展署，移工權益維護報告書，頁2，<https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=1C6028CA080A27B3>（最後瀏覽日：2021年3月6日）。

受僱於適用勞動基準法之行業，享有基本工資、工時等勞動條件之保障；另有關勞工保險條例、職工福利金條例等法令，亦不因其為外籍勞工而受歧視³。

上述宣示，在我國主動將聯合國體系下之數個人權公約內國法化後，對移工勞動條件之平等保護已不只停留在政策層面，更進一步具有法律上拘束力。

而持平以論，臺灣大多數勞動法規，亦確係不分國籍一體適用⁴（某些行業，如私人聘僱之看護，則不分國籍一體不適用勞動基準法⁵），表面觀之，主管機關所稱「工作權益上之國民待遇原則」已獲得滿足。這也是主管機關過去二次面對經濟、社會文化權利國際公約之國際審查時，回復國際審查委員之一貫立場⁶。但審查委員仍表達了對臺灣移工體制的高度憂心：

一個重大關切的議題是移工權利的被濫用和欠缺，這發生在例如人員招募，主要涉及過高的仲介費用、對於雇主幾近完全依賴、轉換雇主的限制、有證勞工失去其身分，以及成為無證⁷勞工後伴隨而來的驅逐出境風險等方面⁸。

³ 勞動部勞力發展署（註2），頁2-3。

⁴ 但仍有少數依國籍區分而給予差別待遇之勞動條件，如就業保險法第5條規定須具中華民國國籍始得為被保險人。

⁵ 家事移工屬於「個人服務業中家事服務業之工作者」，而此一行業係不分國籍一體不適用勞動基準法之保障。1998年12月31日行政院勞工委員會（87）台勞動一字第059604號公告，勞動部勞動法令查詢系統，<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&N2=059604&cnt=1&mode=002&now=1&lnabndn=1&recordno=1>（最後瀏覽日：2020年5月2日）。

⁶ 法務部，經濟社會文化權利國際公約初次國家報告，2012年10月4日，第93點，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/17725/17733/17760/17761/17762/23500/post>（最後瀏覽日：2020年5月20日）。法務部，經濟社會文化權利國際公約第二次國家報告，2016年4月27日，第73點，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12222/4272004131850eed8d.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2021年1月25日）。

⁷ 以下均按國際審查報告之用語，以無證或非正規移工指稱居留與入境身份不完全符合就業國法規之移工，而不以「非法」稱之，乃為避免污名化。如同保護

換言之，勞動法令一體適用的政策與國際公約的規範是一回事，但移工制度離一般想像中所謂平等的勞動體制（例如說移工不是次等勞工，而處於近似於本國勞工地位的狀態），似乎還有一段落差，移工仍在「權利被濫用和欠缺」的狀態。落差的原因可能有很多層面，例如可能法令一體適用是太過形式的平等、又或者勞動法制可能規範密度⁹或執行力度不足等等。但本文將聚焦在一個根本而較少論者觸及的面向，亦即平等原則作為人權法律工具，面對主權國家國界管控權利/權力¹⁰的結構上侷限。

申言之，暫時性跨國移工係處在勞動法與移民法交錯的領域，具有雙重身分，既是勞工、也是外國人。在勞工身分的那一面，移工的勞動條件固受平等保障；然而在外國人身分的那一面，移工制度的核心設計往往來自國境與移民管制的運作，而移民管制的運作邏輯，本質上即建立在本國人與外國人的差別待遇之上——國境管控不僅被視為主權國家最核心的權力之一，且在歷史經驗上，國境管控的崛起與保護內國勞動市場的政策密不可分。人權法係運作在此一國際秩序與歷史經驗之上，連帶地，對國家以國境措施分配就

所有移工及其家庭成員權利國際公約第2號一般性意見第4段所言，使用「非法」一詞，會將這些移工描繪成罪犯，而導致偏見。*Infra* p. 230 & note 61, at ¶ 4.

8 法務部，對中華民國（臺灣）政府落實國際人權公約初次報告之審查國際獨立專家通過的結論性意見與建議，2013年3月1日，第38點，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12490/312259531585.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2020年5月20日）。

9 例如2017年第二次國家人權報告結論性意見與建議提及家事服務法之立法全無進度，這使得所有從事家事服務業之工作者，無論國籍，均處於欠缺基本勞動保障之空窗中。法務部人權大步走計畫，對中華民國（臺灣）政府關於落實國際人權公約第二次報告之審查國際審查委員會通過的結論性意見與建議，2017年1月20日，第31、32點，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12295/3552004141607ed2b9.pdf?mediaDL=true>（最後瀏覽日：2020年5月20日）。

10 國境控制究竟是國家的權力（power）或權利（right），取決於陳述的視角，對於受國境管制的人民而言國家所行使的是權力，但從主權國家本身在國際法上的地位而言，則是相對於其他主權國家之權利。本文則盡量視脈絡不同，選擇合適的字詞使用。

業機會、或不利影響外國人勞動條件，採取寬鬆、退讓之取徑¹¹。

是以本文意在分析：暫時性移工制度對於人權法上外國人勞動權利平等保護的規範與實踐，所造成特殊的、結構性的困難；並以臺灣移工制度實際的運作，佐證上開規範分析與反思制度方向。然而這個議題假使有意義，它必須建立在人權法確實存在保護外國人平等勞動權利的前提上，因此第貳部分即說明人權法，特別是經濟社會文化權利國際公約之下，對於外國人勞動權利平等保護迄今之規範實踐。我們將會看到，在一般而廣泛的工作平等保護宣稱之下，人權法對外國人就業上的權利（right to work）與其在勞動條件上的權利（rights at work）有著不同的處理：前者（就業權利）受制於國境管控，並通常尊重就業國基於經濟政策的判斷；後者（勞動條件權利）原則上不應有基於國籍或法律地位的差別待遇。這種分野展現出人權法在國境和經濟分配之邏輯與普遍之勞動保護間，所面臨的張力以及調和。

但真正困難的是此二領域的交錯：以國境管制為手段之措施——或許意在限縮外國人之就業權利，但卻負面地影響了勞動條件權利，而這正是暫時性移工制度裡，許多典型制度特徵所仰賴的技術。國境之於移工，不只是空間上的必經之途，更型塑了他們作為勞動者的面貌，時時作用在他們的身體、生活與勞動之上¹²。如同 Harald Bauder所指出的，移工是透過國境管制措施，為就業國個別之需求，所量身訂製的特殊勞動力¹³：移民法制藉由對於外國人分

11 Bridget Anderson, *Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers*, 24 WORK EMP. & SOC'Y. 300, 306 (2010).

12 Linda Bosniak, *Persons and Citizens in Constitutional Thought*, 8 INT'L. J. CONST. L. 9, 10 (2010) ("As a matter of fact, the border operates not just at the community's edges but also in its interior, and structures relationships there.").

13 HARALD BAUDER, LABOR MOVEMENT: HOW MIGRATION REGULATES LABOR MARKETS 21 (2006). Bauder以加拿大溫哥華、安大略省和德國柏林不同經濟部門的移工制度為案例，相當重要地指出移民管制體制本身就是勞動力調節的工具。

類、加諸不同的入境條件、使移工處於體制化的不穩定性（precariousness）中，這些控管與限制手段影響了移工進入勞動市場中的條件與待遇¹⁴，進而使其勞雇關係呈現特定的樣貌¹⁵。在這個理論視野下，第參部分將焦點置於臺灣的藍領暫時性移工制度，其意在呈現臺灣發展脈絡下的特定政策取向，以及我國勞動力跨國流動管制的設計，如何回應政策要求。我們會觀察到，移工制度生成的政策時空，對於移工平等勞動權利保護的實踐，不是太友善的背景。

最後，第肆部分藉由4個移工制度的措施（強制定期契約、健康檢查、禁止轉職與行方控制），具體分析移工的勞動地位，是如何以跨境管制的面貌被設計出來。這4項措施都涉及國家透過「暫時性」（temporariness）與「異國性」（alienage）的操演，進而影響到移工重要的勞動條件，但國境管制色彩，卻使得移工外國人的身分壓制過其勞工的身分，勞動平等保護有時甚至是無關之議題。然而，面對此一挑戰，人權法對勞動保護的實踐軌跡，仍能對我們有所啟發：愈是促使移工的勞工地位獨立於其外國人地位，愈有可能避免勞雇權力嚴重失衡的剝削性雇用系統生成，從這個角度，本文亦指出若干可能的修正。

這份研究預期達成3點貢獻：首先，本文提出移工制度須從國境管制的角度理解，才能更切中核心地診斷移工在其中的勞動處境問題，其癥結往往不在於勞動保護規範密度不足，也未必僅因規範貫徹不力，而必須切實面對移民措施的影響。再者，本文系統性地追溯人權法上勞動權利之平等保護，其實踐架構與保障範圍，並藉

14 Anderson, *supra* note 11, at 301. Bridget Anderson指出移民管制透過設立不同的移民類別，形成不同種類的勞動力與不同的勞動關係。移民管制「製造」出群聚於特定部門與次級勞動市場的「不穩定工人」（precarious workers）。

15 Martin Ruhs, *Protecting the Rights of Temporary Migrant Workers: Ideals versus Reality*, in *TEMPORARY LABOUR MIGRATION IN THE GLOBAL ERA: THE REGULATORY CHALLENGES* 299, 301 (Joanna Howe & Rosemary Owens eds., 2016).

此更細緻地分析移工制度對平等保護所造成的內在緊張。最後，本文質疑涉外議題中，國境管制一向優先的預設，將勞動保護與國境管制二者間的緊張關係凸顯出來，以尋求其間的有益對話，反思其優先順序。勞動保護規範所要處理的是，勞工在勞雇關係中可能經歷的特殊脆弱性¹⁶，而此種脆弱性不因國籍有所不同。但當國境透過移工體制擴張至勞動場域運作，往往架空勞動法之本來目的。尋求國境管制與勞動保護間更好的衡平是可能且必要的，而本文可視為是這個方向上的一個初步嘗試。

最後，進入正文之前，有幾點關於研究預設與對象範圍的界定需要說明：

首先，儘管本文批判國境管制對勞動條件之負面影響，但本文原則上不挑戰國家基於領土主權的國境管控權力。相反地，正是因為國家對於移工入境條件有幾近絕對的掌控，我們有理由要求國家對此種權力行使所導致的人權侵害狀態負責——是國家決定了誰可以進入它的管轄領域、以什麼樣的條件進入。國家亦可以選擇不引進任何移工，從而毋庸對外國人負起尊重、保護與實現其勞動人權的義務。然而臺灣既然從無到有地打造了移工制度，它便無從脫免於促使移工制度符合人權規範的任務。

再者，本文並不援引制度外的移民倫理標準（例如是否該更開放或更封閉國界），來衡量人權法與移工體制運作之良窳，不涉及「國境管控是否應當取消」、或「移工制度是否應當廢除」等倫理議題。本文毋寧從官方所自稱的移工平等政策¹⁷及國家主動內國法化

¹⁶ GUY DAVIDOV, A PURPOSIVE APPROACH TO LABOUR LAW 36-48 (2016).

¹⁷ 值得注意的是，國民待遇原則只是官方對於移工權益的面向之一。移工權益維護報告書當中指出我國對外籍勞工之權益有三個基本原則：（1）基本權益上的公平正義原則、（2）工作權益上的國民待遇原則、（3）生活權益上的一視同仁原則。所謂基本權益上的公平正義原則主要指外籍勞工求職過程中，不同中介者之介入分潤是否公平；而生活權益上的一視同仁原則指社會接納與對外籍勞

的國際人權公約出發，檢視其可能的內在矛盾與衝突，或可稱為內在批判的進路，其乍見雖不基進，但若運用得宜可以是有力的制度批判。

第三，本文在制度上的分析對象是臺灣的「藍領暫時性移工」（制度細節詳參第參部分以下），除比較制度差異所需以外，原則上不及於白領移工。概念上，「移工」（或「移徙工人」）原係廣泛指涉在本國以外的國家從事有償活動者¹⁸，並不一定預設居留時間的久暫、或歸化權利之有無；但本文關注的對象是「暫時性移工」（temporary migrant workers），這裡參採的是Martin Ruhs為跨國制度比較研究而設下的定義，是一個實證上的描述，其制度的共同特徵是移工僅憑其受就業國（host state, receiving state）許可合法居留及工作的資格，無從取得申請永久居留或其他長期身分的資格，亦即原則上其居留及工作的期間有所限制，在許可屆期之前必須離境，除非另有得以轉換長期身分的事由¹⁹，亦有文獻稱為客工（guest workers）²⁰。以下行文有時為簡潔考量，會以「客工」指稱「暫時性移工」。至於「藍領」，臺灣對外國人就業採取藍白雙軌制的管

工的生活輔導，「使之人人有歡喜愉悅，賓至如歸的感受」。勞動部勞力發展署（註2），移工權益維護報告書，頁2-3。

官方之政策宣稱或許帶有政治修辭的成分，然而無論是「公平正義」、「國民待遇」與「一視同仁」，都是平等理念下，不同平等觀的展現：「公平正義」指的是分配上的正義；「國民待遇」指向不因國籍不同而予以恣意之差別待遇；「一視同仁」意指提供融入社會生活的必要協助，而為一種實質平等。換言之，官方政策不單以法令上無差別待遇作為目標，而是針對移工跨國遷徙的整個過程，朝向多面向的平等落實。

18 參聯合國保護所有移徙工人及其家庭成員權利公約第2條第1項規定：「『移徙工人』一詞指在其非國民的國家將要、正在或已經從事有報酬活動的人。」G.A. Res. 45/158, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW) art. 2, ¶ 1, *opened for signature* Dec. 18, 1990, U.N. Doc. A/RES/45/158 (entered into force July 1, 2003).

19 Martin Ruhs, *The Potential of Temporary Migration Programmes in Future International Migration Policy*, 145 INT'L LAB. REV. 7, 8 (2006).

20 例如林良榮，我國「外勞（客工）」的勞動人權與社會保障：兼論勞保條例之適用與檢討，台灣國際法季刊，11卷2期，頁51（2014年）。

理，從入境前至出境後之制度一路分離。其中藍領依就業服務法第46條第1項第8至10款²¹規定聘僱，即俗稱之「外勞」，法律上確切之用語為「受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8至11款工作之外國人」，或是雇主聘僱外國人許可及管理辦法第2條所稱之「第二類外國人」，這是本文關注的對象。白領則是非屬上開8至10款規定之外國籍受僱者，白領外籍受僱者仍受國境管控影響²²，但是強度遠低於藍領移工，不受到強制輪替、定期離境、轉職限制等規範，從而非本文所直接關注的對象。

最後，本文在規範上的分析對象是「勞動權利之平等保護」，其中「勞動權利」（有時基於行文順暢也用「工作權利」，但在本文中視為同義）的範圍主要指經濟社會文化權利國際公約第6至8條的內容（詳第貳部分說明），在社會保險涉及就業或工作的範圍內，第9條亦屬之。不過本文細部論點的開展，幾乎集中在個人勞動權（第6條與第7條），而甚少碰觸到集體勞動權（第8條）或社會安全（第9條），這絕非因為後二者的實踐較不重要，僅是因為聚焦於個人勞動權已經足以說明本文的核心論點，受限於篇幅所作的取捨。

貳、外國人勞動權利平等保護之確立與退讓

進入本文，首要呈現的是，國際人權法與勞動法上的勞動保護，與主權國家控制國界之權力間，所存在的規範張力。一方面人權法確立了勞動權利應為所有人平等享有的原則，但他方面主權國家對外國人入出境條件享有廣泛的裁量，並以此作為保護或調節內

21 這三款分別是：「八、海洋漁撈工作。九、家庭幫傭及看護工作。十、為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要，經中央主管機關指定之工作。」

22 SANDRO MEZZADRA & BRETT NEILSON, BORDER AS METHOD, OR, THE MULTIPLICATION OF LABOR 141 (2013). Mezzadra與Neilson指出即使是所謂的「技術」移工，一樣可能面臨跨境勞動對其專業的降格。

國勞動市場的工具，而人權法大致上不挑戰國境管制的邏輯與秩序。其結果是，在普世而一般性的工作平等保障下，廣泛地容許國家基於國籍和移民地位不同所施加之差別待遇。

以下第一節將先確立外國人勞動權利的平等保護在國際法上的來源、範圍與內涵；第二節則進一步分析，勞動權的平等保護在主權國家邊界控管前之限縮。

一、外國人平等勞動權利之確立

外國人是否受勞動權利保障？尤其是平等的勞動權利保障？在國際人權法上答案是肯定的²³，且所謂勞動權利的範圍，原則上包含就業上的權利與勞動條件上的權利。其中最直接、也與臺灣最相關的依據，是聯合國經濟社會及文化權利國際公約²⁴（下稱「經社文公約」）有關工作權與平等原則之規定與實踐。此外，受經濟社會文化權利委員會（下稱「經社文委員會」）援引之與移工相關的國際公約規定和實踐，也是解釋上重要的依據。

（一）經社文公約

首先，從工作權的角度觀之，經社文公約所定之勞動相關權利，就「人」的適用範圍上是普遍的。一般說來，人權公約適用對象之範圍，除非有明文的排除²⁵，否則及於所有人²⁶；而經社文公

23 *E.g.*, MANISULI SSENIONJO, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW 425 (2d ed. 2016); BEN SAUL, DAVID KINLEY & JAQUELINE MOWBRAY, THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS: COMMENTARY, CASES, AND MATERIALS 315 (2014).

24 G.A. Res. 2200A (XXI), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, *opened for signature* Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3 (entered into force Jan. 3, 1976). 條文之中文參考法務部，全國法規資料庫，<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0000038>（最後瀏覽日：2019年8月12日），以下均同。

25 例如歐洲社會憲章（European Social Charter）之社會經濟權，明文限於締約國之本國國民，與屬於其他締約國國民、且合法在締約國境內居留工作之外國人，始有適用，排除非屬締約國國民之外國人。Council of Europe, European

約落實之重要指引林堡原則（Limburg Principles），也重申公約之權利，原則上適用於外國人與本國人²⁷。公約第6條第1項規定自由選擇工作之權利；第7條規定公平而良好工作條件之權利、性別同工同酬保障及平等之升遷機會；第8條規定組成與加入所選工會之集體勞動權。這些條文之用語，均規定為「人人有權……」（the right of everyone to...），是以至少在文字上，第6至8條的勞動權利，潛在地及於所有人。

公約第6條所涉及的就業上的權利，可能會引發較多關於適用對象範圍的疑慮，但經社文公約第18號一般性意見針公約對第6條規定，清楚地說明其保障對象範圍包含外國人，且就業之平等是就業選擇權利之一部。經社文委員會指出：公約第6條所例示的權利內容，包括每個人有權自由選擇工作、不受強制工作、亦不被不公平地剝奪工作的權利²⁸。而欲使人能投入各種形式工作，「可近性」（accessibility）是不可或缺的，可近性意謂著「勞動市場必須向締約國管轄下的所有人開放」²⁹。經社文委員會並援引公約第2條第2

Social Charter (Revised), at Part I ¶¶ 18, 19, *opened for signature* May, 3 1996, E.T.S. No.163 (entered into force July,1 1999).

26 M. MAGDALENA SEPÚLVEDA, THE NATURE OF THE OBLIGATIONS UNDER THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 259 (2003).

27 U.N. Commission on Human Rights [hereinafter UNCHR], *Note verbale dated 5 December 1986 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations Office at Geneva addressed to the Centre for Human Rights* (“Limburg Principles”), ¶ 42, 43rd Sess., U.N. Doc. E/CN.4/1987/17 (Jan. 8, 1987).

28 Economic and Social Council [hereinafter ECOSOC], Comm. on Econ., Soc. and Cultural Rights, *The Right to Work, General Comment No. 18, Adopted on 24 November 2005, Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, ¶ 6, 35th Sess., U.N. Doc. E/C.12/GC/18 (Feb. 6, 2006).

經濟社會文化公約一般性意見之中文，本文係參考司法院法學資料檢索系統收錄之版本，<https://law.judicial.gov.tw/FLAW/dat02.aspx?lsid=FL070448>（最後瀏覽日：2019年9月21日），以下均同。

29 *Id.* at ¶ 12(b). (“The labour market must be open to **everyone under the jurisdiction of States parties.**”) (emphasis added.)

項（詳下說明）及第3條³⁰規定，與國際勞工組織（ILO）第111號公約第2條³¹規定（詳下說明），指出締約國必須致力於消除對受到邊緣化之團體的就業歧視³²，而邊緣化的團體包括移工在內³³。針對移工，經社文委員會援引保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約³⁴（下稱「移工公約」），指出移工公約第7條（詳下說明）所闡釋之不歧視原則，應適用於移工及其家庭成員之就業機會，並強調締約國需有計畫地透過立法或其他措施，尊重、促進不歧視原則的實現³⁵。

公約第7條涉及勞動條件上的權利，第23號一般性意見針對第7條，除了闡釋包含公允的工資、安全健康的工作條件、平等升遷的機會、及合理的工時與休息等工作條件，就其保障對象，則重申享受公平與良好的工作條件的權利，適用於所有場所的所有工人，不分是否為移徙工人³⁶，其並指出，無證移工尤其「易遭剝削、被迫長時間工作、接受不公平工資以及危險和有害健康的工作環境」，故應以法律或政策確保，移工在報酬與工作條件上不遭受劣於本國工人之待遇³⁷。這些敘述顯示經社文委員會充分意識到「所有工人」包含無證移工，而法律身分不應影響其工作條件。

30 第3條：「公約締約國承允確保本公約所載一切經濟社會文化權利之享受，男女權利一律平等。」

31 第2條：「凡受本公約效力約束之會員國應宣示並遵循一旨在依適合國情及習慣之方法以促進僱傭與職業方面機會均等及待遇平等之國家政策，俾消除在此方面之歧視。」

32 UNCHR, *supra* note 27, at ¶ 12(b)(1).

33 *Id.* at ¶ 23.

34 ICRMW, *supra* note 18.

35 UNCHR, *supra* note 27, at ¶ 18.

36 ECOSOC, Comm. on Econ., Soc. and Cultural Rights, *General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, ¶¶ 5, 65(a), 44th Sess., U.N. Doc. E/C.12/GC/23 (Apr. 7, 2016).

37 *Id.* at ¶ 47(e).

再者，從平等原則的層面觀之，經社文公約下之平等保護，其適用對象同樣包括外國人，且擴及禁止基於國籍之歧視。儘管公約第2條第2項「本公約締約國承允保證人人行使本公約所載之各種權利，不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或其他主張、民族本源（national origin）或社會階級、財產、出生或其他身分等等而受歧視。」之規定（粗體為筆者所強調），表面上未將「國籍」或「移民地位」明文羅列為不得為差別待遇之分類基準，但該規定在立法技術上是例示而非列舉³⁸，而經社文公約第20號一般性意見針對第2條第2項規定進一步指出，所謂「其他身分」，係指與明文應受平等保護的特徵可堪比擬的特徵，而一般承認，帶有這些特徵的人們，經歷長久邊緣化的弱勢地位³⁹。國籍包含在「其他身分」中，不應是享有公約權利的障礙，公約權利應不分國籍，亦不論其法律地位與身分文件，適用於所有人，包含移工在內的非國民⁴⁰。本項規定搭配公約第6至8條，亦構成對於外國人勞動權利平等保護之要求。

經社文公約第2條第2項的不歧視原則，在性質上屬於立即義務，「不受逐步實施限制，也不依賴可得資源的多寡。它直接適用工作權的所有面向」⁴¹。不過，平等保護或禁止歧視，並不表示不可以存在任何差別待遇，而是要求差別待遇需有合理、客觀的正當

38 UNCHR, *Limburg Principles*, *supra* note 27, at ¶ 36. See also MATTHEW C. R. CRAVEN, *THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS: A PERSPECTIVE ON ITS DEVELOPMENT* 168 (1995).

39 ECOSOC, Comm. on Econ., Soc. and Cultural Rights, *General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, ¶ 27, 42nd Sess., U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (July 2, 2009).

經濟社會文化公約一般性意見之中文，本文係參考司法院，法學資料檢索系統，<https://law.judicial.gov.tw/FLAW/dat02.aspx?lsid=FL070448>（最後瀏覽日：2019年9月21日），以下均同。

40 *Id.* at ¶ 30.

41 UNCHR, *supra* note 27, at ¶ 33.

基礎，包括採取差別待遇措施的目的與效果是否正當合法、是否與公約之權利相容、是否係為促進民主社會中的一般福祉、又手段與目的間是否合比例等⁴²。在以下第二節，會再談及。

值得特別注意的是，上開人權法上的平等規範對我國就業平等法制有重要啟示，因為就業服務法第5條第1項有關就業平等之規定⁴³，係完全將非國民（non-nationals）排除在保護範圍外⁴⁴，並刻意排除「國籍」歧視之禁止⁴⁵，而與經社文公約第2條第2項規定衝突。不過行政實務上，勞動主管機關以較周延之函示，援引ILO平等保護之精神⁴⁶，將就業服務法第5條第1項之保護範圍，擴張至六

42 *Id.* at ¶ 13.

43 第5條第1項：「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。」（粗體為筆者所強調）

44 比較林佳和，從國際人權的政治哲學觀談台灣的外國移工人權——兼論人權、勞動市場、產業競爭力的交錯與衝突，台灣國際法季刊，11卷2期，頁33（2014年）。其似認為就業服務法第5條規定適用於外國人（不限於保護國民），而對於移工的歧視則構成種族歧視。然而，本文認為，立法者係有意將外國人完全排除在第5條範圍外，因為最早就業服務法第5條草案規定方式並無「為保障國民就業機會平等」之文字，而是「雇主對求職者或受僱者……不得因性別或性傾向而有差別待遇」（粗體為筆者所強調），在二讀過程中始改為現行規定方式。比較立法院公報，79卷82期，議案關係文書頁15（1990年）（行政院1990年草案）與立法院公報，81卷19期，議案關係文書頁17（1992年）（二讀之草案）。

45 對「國籍歧視」不予保障，亦是立法者有意之決定，因就業服務法是在引進移工的背景下制訂，整個藍領移工的引進制度，都是建立在基於國籍的差別待遇之上，立法討論過程即有委員指出，須排除在平等保障範圍外以免困擾。例如立法院公報，80卷97期，頁37-38，黃天生委員發言（1991年）。

46 行政院勞工委員會2012年7月24日勞職業字第1010073004號函。這號函示係因臺北市勞工局質疑這六類人員不持有身分證，非屬第5條第1項所稱之「國民」，是否確有該條就業平等之適用？但行政院勞工委員會的回函避開「國民」與否的定義，而是強調「工作『平等』」，是國際勞動組織所彰顯勞動者基本人權；不論已開發國家或開發中國家，各態樣就業歧視之禁止，其重要性已逐漸凌駕一般傳統勞資爭議問題，是「雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言對勞工有所差別待遇」。又行政院勞工委員會2013年1月17日勞職業字第1020501049號函，則以出生地歧視的概念處理對非國民之就業歧視：「雇主用人選擇應以工作性質、需求及受僱者工作能力為考量，如限定須

類不持有國民身分證，但因工作、結婚、依親等事由，得合法居留與工作之非國民⁴⁷，緩和了內國法與人權法的落差⁴⁸。

最後附帶一提，經社文公約第2條第3項⁴⁹允許發展中國家基於國籍而就外國人之經濟權利予差別待遇，這是外國人受公約平等保護的唯一明文例外，但對本文所探討的核心對象——跨國藍領客工而言，並不能援用第3項規定，來作為對外國人工作權給予差別待遇的依據。這是因為第3項制訂的背景在於保護前殖民地國家的經濟自主，尤其是防止前宗主國國民繼續把持經濟命脈⁵⁰，因此解釋上適用情形頗為狹窄，而客工顯非對前殖民地從事經濟剝削的前宗主國政商階層。又證諸實務，第3項沒有被制定時所欲保護的發展中國家援引過，因而在當代的人權實踐中可說是逐漸失去重要性⁵¹。最後，亦有論者藉第3項的明文例外反面推論，主張除受第3項規定所容許者外，其他經濟權的國籍差別待遇即非公約所許，例如已開發國家即不得限制外國人就業機會⁵²。從這個角度，第3項規定（藉反面推論）甚而可能是強化客工不應受差別待遇之理由。

具備『中華民國身分證者』，即涉違反本法第5條第1項禁止『出生地』就業歧視之虞。」

47 包含外國人、中國人民與香港、澳門地區人民。就業服務法裡所稱的「國民」，本意應指領有身分證的「有戶籍國民」，因此在本文的脈絡裡，將「無戶籍國民」界定為非國民。在我國特殊的體制下，戶籍實質替代了國籍的作用，而有所謂「有戶籍國民」與「無戶籍國民」之分，後者包含中國、港澳、與僑民，參入出國及移民法第3條第4款、第5款；臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第3款、第4款；香港澳門關係條例第3條、第4條。

48 不過，雖有函示的補充，本文認為就業服務法之文字仍應修正以符公約精神。姑不論種族、階級、語言、出生地等概念與國籍並不相同，更重要的是就業服務法第5條第1項對於雇主所課予的就業平等義務附有罰則，因此若就業平等確實擴張至外國人，國家即應致力於條文文字之明確化，以提高雇主對其義務的可預見性。

49 該項規定為：「發展中國家在適當顧及人權及國民經濟之情形下，得決定保證非本國國民享受本公約所確認經濟權利之程度」。

50 SEPÚLVEDA, *supra* note 26, at 414.

51 Haina Lu, *The Personal Application of the Right to Work in the Age of Migration*, 26 NETH. Q. HUM. RTS. 43-77, 47 (2008).

52 CRAVEN, *supra* note 38, at 213.

(二) ILO第111號公約與移工公約

除了經社文公約，其他國際文件也有不少關於平等工作權及於非國民之規範與實踐。為免繁雜，這裡僅舉前述經社文委員會援用、且對我國亦具有規範上重要性的二份文件來說明：ILO 1958年僱傭與職業歧視公約（即第111號公約）⁵³和移工公約。

ILO第111號公約在我國應受重視，不僅在於其為經社文委員會援用，亦因第111號公約是ILO勞動基準保障的8個核心公約（Core Labour Standards, Fundamental ILO Conventions）之一，更重要的是其業經我國批准⁵⁴，為我國法律體系之一部分⁵⁵，不受退出ILO之影響⁵⁶。

⁵³ International Labour Organization [hereinafter ILO], Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, *opened for signature* June 25, 1958, 5181 U.N.T.S. 362 (entered into force June 15, 1960).

此處ILO第111號公約的中譯，係參考勞動部（前身行政院勞工委員會）所編印之國際勞工公約，<https://www.mol.gov.tw/media/77317/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%85%AC%E7%B4%84.pdf>（最後瀏覽日：2019年9月21日）。但有些ILO公約中譯的品質不理想，遇此情形則本文則不再參考勞動部版本，而自行翻譯。

⁵⁴ 1961年7月25日由立法院通過，1961年9月7日總統批准，1963年2月13日起對我國生效。以上參立法院公報，27會期第16期，頁25（1961年）；總統府公報，1260號，頁1-2（1961年）；總統府公報，1421期，頁5-7（1963年）。

⁵⁵ 司法院釋字第329號解釋理由書第1段參照。

⁵⁶ 在我國退出ILO之後，過去批准的公約是否仍舊有效，在學界似有不同見解。不過本文認為依維也納條約法公約，條約完成批准之法定程序而生效後，其效力不因嗣後退出國際組織而受到影響，退出ILO所影響的是履行方式，因臺灣之後並非ILO成員國，公約之履行不受ILO的監督。有幾位論者結論與本文近似，但各基於不同理由，例如黃舒芃從內國法效力的觀點，認為其既已構成內國法一部份，規範效力及地位已經確立，不受退出國際組織之影響。黃舒芃，國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色：兼評司法院釋憲實務對國際及區域人權公約之看待與引用方式，臺灣民主季刊，13卷1期，頁103註8（2016年）；徐揮彥認為ILO之核心勞動基準在解釋上已具備國際法中強行法的性質，徐揮彥，從高捷泰勞事件淺論禁止強迫勞動相關國際人權規範之內涵及落實，台灣本土法學雜誌，83期，頁84（2006年）；劉士豪、羅國應認為ILO公約為普世價值，可為我國勞動法法源，劉士豪、羅國應，批准「兩公約」對我國勞動法制之影響——論其與ILO公約及建議書之關係，台灣國際法季刊，7卷4期，頁34（2010年）。

ILO第111號公約第1條第1項對歧視的定義原本避開「國籍」：「基於種族、膚色、性別、宗教、政治主張、血統或社會門閥所作足以損害或取消僱傭與職業方面之機會均等或待遇平等之區別、排斥或優先」。其中採用「血統」(national extraction)，而不是更常見的「民族本源」(national origin) (如上述經社文公約第2條第2項所列)，本是為了避免條文被誤解為其禁止基於國籍的就業上差別待遇⁵⁷。不過，儘管其規定方式刻意縮小歧視定義，致其表面上顯得比經社文公約的保護範圍為窄，但是第111號公約之實踐顯示，基於國籍之差別待遇仍被認為有違反公約之嫌疑。一方面，作為實踐ILO 4項基本原則之核心公約之一，其適用須及於所有工人，無論其國籍與法律地位⁵⁸；他方面，專家委員會針對第111號公約所提出之報告，相當關切各會員國以國籍區別標準，對移工所為之差別待遇，並指出國籍歧視易於與種族、宗教等因素混雜難分⁵⁹。

至於移工公約，儘管臺灣並未簽署或將之內國法化，但間接地透過經社文公約第18號一般性意見援引移工公約第7條，論及締約

⁵⁷ Henrik Karl Nielsen, *The Concept of Discrimination in Ilo Convention No.111*, 43 INT'L. & COMP. L. Q. 827, 840 (1994).

⁵⁸ International Labour Conference [hereinafter ILC], *Giving Globalization a Human Face: General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008*, on ILC 101st Sess., ¶¶ 776-778 ILC.101/III/1B at 325 (2012), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf.

⁵⁹ 在ILO關於工作基本原則與權利宣言之下2011年針對就業平等所撰寫的全球報告中，指出基於國籍的歧視易於與種族、族群、宗教等歧視混和，不易區別。此外，移工的處境易於涉及歧視，而相關案例許多都涉及到暫時性移工制度典型的特徵，例如韓國只容許移工在很少數情況下轉換雇主，而雇主若違規移工也會連帶失去工作的許可，卡達要求所有的移工必須要有雇主支持才可繼續留在境內，波灣國家不讓移工有領取老年退休給付的資格、馬來西亞與新加坡在經濟情勢不樂觀時鼓勵雇主優先解雇移工等。ILC, *Report I(B)-Equality at Work: The Continuing Challenge, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, on ILC 100th Sess., at 34, 36 (2011), https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/100thSession/reports/reports-submitted/WCMS_154779/lang--en/index.htm.

國有立法尊重、促進移工及其家庭成員就業機會不受歧視，即是在帶進移工公約的視野，補充經社文公約的內涵，也是於此脈絡下，移工公約對臺灣有所規範意義。

移工公約的重要性是它確立了一系列所有移工（無論法律地位）⁶⁰均一體適用的核心權利：包括第7條之平等保護，即要求締約國對管轄範圍內的所有移工及其家庭成員，保護其不受基於國籍或其他身分之差別待遇、第11條不受奴役及強迫勞動、第22條不受集體驅逐、第25條就工作報酬、工作條件和雇用條件享有不低於國民之待遇、第26條參與工會等等。從而再度確認，國籍和法律身分都不是當然構成工作權利上正當差別待遇的理由。移工公約第2號一般性意見並指出，差別待遇須依法為之，旨在實現公約所定的正當目標，並為實現該目標之必要、適當手段⁶¹。

最後，許多論者會質疑移工公約的效果，指出移工公約締約國少，又多為移工輸出國⁶²，意指這些保障過於基進——尤其是無證移工之保障，而無法為許多國家接受。不過若因此忽視移工公約規範的訊息，可能就落入了締約國數字的迷思。因為移工公約的核心內容分析起來，許多不過就是重申其他廣受簽署之人權公約的內

60 在這點上，移工公約與主要適用於有證移工之ILO第97及第143號公約相較，是重要的進展（以下第二部分會提到更多此二公約的規定）。

61 Comm. on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, *General comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their families*, ¶ 18, 18th Sess., U.N. Doc. CMW/C/GC/2 (Aug. 23, 2013).

62 E.g., DAVID S. WEISSBRODT, *THE HUMAN RIGHTS OF NON-CITIZENS* 188 (2008); Paul De Guchteneire & Antoine Pécoud, *Introduction: The UN Convention on Migrant Workers' Rights*, in *MIGRATION AND HUMAN RIGHTS: THE UNITED NATIONS CONVENTION ON MIGRANT WORKERS' RIGHTS* 1, 14-25 (Ryszard I. Cholewinski et al. eds., 2009).

截至2019年移工公約有55個締約會員國，相較於經社文公約有170個締約會員國；公政公約有173個締約會員國。U.N. Human Rights Office of the High Commissioner, *Status of Ratification Interactive Dashboard*, <https://indicators.ohchr.org/> (last visited Oct. 20, 2019).

容，本就拘束包括臺灣在內的多數國家。透過其他人權公約實踐上的相互援引，部分移工公約規範亦已產生遠超出移工公約締約國的效應⁶³——此種移工保護國際規範，以一般性的人權規範作為槓桿，而發揮更大影響力的趨勢⁶⁴，不應被忽視。

二、外國人平等勞動權利之退讓

儘管上一節分析人權法迄今的規範內容，係對所有人提供平等工作權之一般保障，但主權國家仍有各種方式可以使外國人之勞動權利無從行使或受到限制，最重要而直接的是透過國境控管，排除外國人入境或設定入境居留之條件。

用國境管制的技術來控制勞力流動，絕非偶然。因為歷史經驗上，國境控管權力與技術的興起，與國家積極介入調節勞動市場的過程密不可分。申言之，我們今日熟知的「國家對國境管控享有幾近絕對權力」的國際法秩序，是相對晚近的規範現象。19世紀因跨洲交通的進步，原本被稱為跨國移動的黃金年代⁶⁵，人員出入之自

63 Bernard Ryan & Virginia Mantouvalou, *The Labour and Social Rights of Migrants in International Law*, in HUMAN RIGHTS AND IMMIGRATION 177, 210 (Ruth Rubio-Marín ed., 2014).

64 在ILO系統下也有類似現象：針對移工保護的第97號與第143號公約批准國的數量不多，但是ILO第111號公約則獲得廣泛簽署，而第111號建議書乃援引第97號公約的內容來強調對移工所應提供之保護，使保護移工之公約藉由充實一般性公約條款的內容，而有更大影響力。Shauna Olney & Ryszard Cholewinski, *Migrant Workers and the Right to Non-discrimination and Equality*, in MIGRANTS AT WORK: IMMIGRATION AND VULNERABILITY IN LABOUR LAW 259, 271 (Cathryn Costello & Mark Freedland eds., 2014).

65 Catherine Collomp, *Labour Unions and the Nationalisation of Immigration Restriction in the United States, 1880-1924*, in MIGRATION CONTROL IN THE NORTH ATLANTIC WORLD: THE EVOLUTION OF STATE PRACTICES IN EUROPE AND THE UNITED STATES FROM THE FRENCH REVOLUTION TO THE INTER-WAR PERIOD 237, 237 (Andreas Fahrmeir et al. eds., 2003). Cf. David Feldman, *Was the Nineteenth Century a Golden Age for Immigrants? The Changing Articulation of National, Local and Voluntary Controls*, in MIGRATION CONTROL IN THE NORTH ATLANTIC WORLD: THE EVOLUTION OF STATE PRACTICES IN EUROPE AND THE UNITED STATES FROM THE FRENCH REVOLUTION TO THE INTER-WAR PERIOD 167, 167-77 (Andreas Fahrmeir et al. eds., 2003).

由放任係為主流⁶⁶。但19世紀末到二次大戰之間，歐洲與北美國家，卻從原本的自由放任轉變為積極壟斷人員跨國界移動之管理⁶⁷，並介入外國勞動力的招募或排除，移民管制法律紛紛興起，終至翻轉主流規範秩序。究其轉變原因，除了各國內部種族主義排外勢力的興起⁶⁸，更與工會運動推動移民管制的訴求息息相關：工會指控外來勞工拉低薪資、輕易接受惡劣工作條件、破壞罷工⁶⁹，以此為由推動保護內國勞動市場的立法⁷⁰。此外，福利制度（尤其失業保險）的發展和投票權的推進，亦使國家越來越有必要精確地分辨居民的國籍與其身分資格⁷¹，而民主政治的擴展，也鼓勵政治

66 VINCENT CHETAIL, *INTERNATIONAL MIGRATION LAW* 40 (2019).

67 JOHN C. TORPEY, *THE INVENTION OF THE PASSPORT: SURVEILLANCE, CITIZENSHIP AND THE STATE* 8-11 (2d ed. 2018). Tropey指出護照以及其他移民文件的發明與趨同的歷史進程，就是國家排除其他次級政治組織（如城市）或私人團體（如教會）介入人之跨境移動、壟斷合法移徙方式（monopolization of legitimate means of movement）的過程。

68 MARILYN LAKE & HENRY REYNOLDS, *DRAWING THE GLOBAL COLOUR LINE: WHITE MEN'S COUNTRIES AND THE INTERNATIONAL CHALLENGE OF RACIAL EQUALITY* 310-31 (2008); ADAM M. MCKEOWN, *MELANCHOLY ORDER: ASIAN MIGRATION AND THE GLOBALIZATION OF BORDERS* 217-38 (2d ed. 2011). Lake與Reynolds很生動地勾勒出白人墾殖國家，從19世紀末到1920年代在所謂為白人守住一方淨土的各種政治修辭與移民政策上，如何彼此應和、相互影響，尤其是白澳政策與美國排華運動間的連動。Adam M. McKeown則指出移民管制和個人身分識別及旅行證件的興起，並非是所謂傳統主權自然的產物，而是19世紀的全球化背景下，各種試圖排拒亞洲人跨洋旅行之措施的歷史產物。

69 Leo Lucassen, *The Great War and the Origins of Migration Control in Western Europe and the United States (1880-1920)*, in *REGULATION OF MIGRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCES* 45, 48 (Anita Böcker et al. eds., 1998).

70 Collomp, *supra* note 65, at 237. Collomp以美國1882-1924年間之美國工會串聯為例，說明全國性的工會聯合組織，藉由排華（或排亞）議題，及推動緊縮移民政策，一致對外，以整合內部歧見。因為這個背景，勞動市場管制與種族排外動機交纏不清，故美國至1965年以前的種族限額移民政策（亦即就不同種族設定移民入境配額數量），主要是針對經濟移民，其他如學生、依親，不會受到種族性配額的影響。Collomp, *supra*, at 249.

除了美國以外，歐洲亦不能免於種族張力，如法國排斥義大利工人、德國排斥波蘭工人、英國排斥猶太與羅姆人，並制訂限制其入境的相應立法。Lucassen, *supra* note 69, at 47-52.

71 Leo Lucassen認為本國勞工對於外國工人的排拒與工會運動合流，只能部分解釋國界管制為何從開放到緊縮的，因為外國工人入境後也可能成為工會的盟

人物提倡據信可以保護國內經濟與薪資的國界管制措施⁷²。一戰期間，強化之移民管制是排除敵方人民的應戰策略，但管制卻未隨戰爭結束而開放，更因戰後經濟大蕭條之故，繼續延續下來，以保護國內勞動市場⁷³。而領土主權概念更為大幅變動的人員移動管制秩序提供理論基礎⁷⁴。

今日的人權法規範，乃是建立在上述以國境管控勞動力之歷史遺產與國際秩序上⁷⁵。由此觀之，經社文公約未改變「外國人並無入境求職的一般性權利」的國際法規範⁷⁶，即不令人驚訝。大多數締約國對外國人進入內國勞動市場均仍加諸限制，而非平等開放，也反映了它們對主流國際法秩序的理解⁷⁷。

友，而降低對外國工人之排拒感，且政府政策與工會立場不一定同陣線。Lucassen因而認為社會安全制度與福利國家發展，可以補充種族與工會運動在解釋上的不足。Lucassen, *supra* note 69, at 53-55.

72 MCKEOWN, *supra* note 68, at 321.

一個重要的問題是，並不是所有的國家都有種族排外、工會運動、社會福利與投票權的擴張，所以這些因素是否真能解釋全球自由流動秩序的終結？McKeown認為這是移民管制的驅同現象：當移民管控的模式與技術在美國與歐洲國家建立後，成為流行且難以取代的人口流動管理制度與意識形態。影響所及，即使少有移民、也沒有出現加強國境控管因素（如社會福利制度、投票權、移民潮、工業化的勞力需求等）的國家，也開始採用類似的標準移民管控模式，而不論自己有沒有執行這套移民管制技模式的能力。因為必須追隨這套移民控制的主流架構，才會在國際上被認可為自治的現代主權，顯出參與全球秩序的意圖，否則就是拒絕成為文明國家、排斥科學方法、自外於世界歷史進程。MCKEOWN, *supra*, at 322.

73 CHETAIL, *supra* note 66, at 48.

74 *Id.* at 49.

75 筆者感謝審查人指出移民管制與勞動市場管制和福利國家興起，其間關聯性的重要方向。

76 SAUL, KINLEY & MOWBRAY, *supra* note 23, at 316.

77 *Id.* at 317.

有少數國家在批准經社文公約時，提出保留或澄清，主張其不因經社文公約第6條而不得對外國人求職加諸有關出生地、居住地等等資格限制，而未見其他締約國不反對，這表示各締約國至少不認為拒絕平等開放就業機會給外國人，會與經社文公約之目的不相容。CRAVEN, *supra* note 38, at 214; SAUL, KINLEY & MOWBRAY, *supra* note 23, at 317.

以下即從跨境、居留與身分分類三個面向，說明一般性的勞動權利平等保護規範的退讓：

(一) 單向之跨境移徙自由

如前所略提及，在西伐利亞體系（Westphalian system）的領土主權概念下，保護領土完整，包括維護國界與控制外來移民入出的權力，是國家主權的核心內涵之一⁷⁸，特別是在全球化時代下，控制人流入出境被視為國家最後的主權堡壘⁷⁹。建立在主權秩序下的人權法，其移徙自由（freedom of movement）在出國及入國之間並不對稱。聯合國世界人權宣言第13條第2項規定：「人人有權離去任何國家，連其本國在內，並有權歸返其本國。」類似地，公民權利與政治權利國際公約（下稱「公政公約」）第12條第2項與第4項規定：「人人應有自由離去任何國家，連其本國在內」；「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」。也就是說，人權法承認人有出國的權利，但原則上沒有入境他國的權利，僅能入境回本國⁸⁰。

外國人要能主張工作權利上的平等待遇之前，他得先能「在這裡」（being here），也就是入境並居留⁸¹。惟現行的國際法秩序下，既然外國人跨國境移動的權利幾乎不存在，外國人也就沒有一般

78 Richard Perruchoud, *State Sovereignty and Freedom of Movement*, in FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL MIGRATION LAW 123, 125 (Brian Opeskin et al. eds., 2012).

79 Catherine Dauvergne, *Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times*, 67 MOD. L. REV. 588, 588 (2004).

80 需注意的是「本國」不是嚴格地指具有法律上國籍之國，公政公約第27號一般性意見第4段指出，第12條的權利，不區分本國人或外國人享有，而第4項的用語本國（his own country）範圍比起國籍國（country of his nationality）廣，包括許多雖然未享有法律上正式的國籍但與該國有所聯繫的情況，例如長期居留者，緊密的家庭關係或者被不當拒絕該國國籍的無國籍人。
U.N. Human Rights Comm'n, *CCPR General Comment No. 27: Freedom of Movement (Article 12)*, ¶ 4, 67th Sess., U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (Nov. 2, 1999).

81 Linda Bosniak, *Being Here: Ethical Territoriality and the Rights of Immigrants*, 8 THEOR. INQ. L. 389, 390 (2007); Chantal Thomas, *Convergences and Divergences in International Legal Norms on Migrant Labor*, 32 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 405, 411 (2011).

性、無條件到他國謀職的權利⁸²。其入境停留或居留均須符合入境國所訂之消極或積極的條件，也就是符合於該國認可准予入境的外國人類別，例如觀光、依親、投資、受僱等⁸³，且無法定不得入境事由⁸⁴。國家對這些條件一般而言可以自由裁量決定，無論是人數上限、事由、效期、准予在境內從事的活動，以及在何種情況下停留或居留之許可將遭到撤銷等⁸⁵。

而為了保護內國勞動市場，排除外國人入境的措施，雖涉及國籍或出生地之差別待遇，通常會被視為係客觀而合理的區別，而非歧視。除非是單獨挑出個別國家不准其國民入境，才會引發國籍歧視的嫌疑；反之，獨厚某些國家國民，容許其入境求職則不被認為涉及歧視問題⁸⁶。

在此脈絡下，即便是移工保護之相關公約，也一再確認國家之國境管制不受公約所訂移工權利之影響：移工公約第79條規定，公約不影響國家訂定移工之出入境標準的權利。移工公約第2號一般性意見指出，此一規定係在體現二個利益之間的平衡，一是締約國控制國界、以及管制移工入境居留的主權，二是締約國對移工根據公約規定提供權利保障⁸⁷。類似地，ILO系統下針對移工所訂之第97及143號公約，實踐上都強調其不涉及國家決定移工出入境條件權力，例如ILO專家委員會2016年在有關各個移工保護公約的調查報告中指出，公約第143號第10條有關就業平等的規定，並不影響會員國許可或拒絕外國人入境的權利，也不涉及發放和更新工作許

82 SSENIONJO, *supra* note 23, at 422; SAUL, KINLEY & MOWBRAY, *supra* note 23, at 315.

83 例如入出國及移民法第23條所定各款。

84 例如入出國及移民法第18條所定各款。

85 主權國家控制國境的權利還是有一些少數的例外，一是對於不遣返原則與對難民的責任，CHETAIL, *supra* note 66, at 155；二是不歧視原則，特別是種族歧視。Thomas, *supra* note 81, at 412.

86 SAUL, KINLEY & MOWBRAY, *supra* note 23, at 316.

87 *Supra* note 61, ¶ 13.

可的相關規定⁸⁸。總之，在入境控制上國家享有幾乎絕對的裁量，人權法相對不涉入。

(二) 移工之低度居留保障

國境管控不止可以排除外國人，也控制其居留。當外國人處在非其本國境內時，他必須是合法入境，且持續地處於合法居留的狀況下，才能享有在外國境內之遷徙自由以及選擇居住所的權利。而即便是合法入境及居留，國家也有權將之驅逐出境⁸⁹。人權法上的保護，主要是程序層面：例如依公政公約第13條規定，對外國人之驅逐重要的是須按法定理由與法定程序為之⁹⁰。又例如經社文委員會亦指出，若恣意驅逐移工而無適當的補償，會構成工作權之違反，而集體驅逐常被認為構成「恣意」。如利比亞以無事實根據的理由，包括惡化治安、傳染疾病、從事黑市交易等，集體驅逐數千名移工，被認為係違反公約⁹¹。類似地，移工公約第22條規定不得集體驅逐移工，案件必須個別審查，並提供相關的程序保護。這些保障都很重要，但原則上均不涉及實體保護，而偏向於強調依法行政⁹²。

88 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations [hereinafter CEACR], *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Articles 19, 22 and 35 of the Constitution): General Survey Concerning the Migrant Workers Instruments*, ¶ 350, 105th ILC Sess. (2016), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf.

89 CHETAIL, *supra* note 66, at 155.

90 International Covenant on Civil and Political Rights, *opened for signature* Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into force Mar. 23, 1976).

以下隨即會提到移工保護諸公約所提供的若干實體保護。但除此之外，公政公約第7條提供了對外國人最重要的實體上不得驅逐的事由，即不得遣返原則 (the principle of non-refoulement)，禁止將外國人強制遣返至有可能遭到迫害或虐待之地。此亦隨公政公約之內國法化而有拘束力，不得遣返原則的適用並不區分外國人有證或無證，僅考慮其實際風險。

91 CESCR, *Concluding Observations: Libyan Arab Jamahiriya*, ¶ 16, UN Doc. E/C.12/1/Add.15 (May 20, 1997).

92 在我國憲法下亦然，司法院釋字第708號解釋重要地確保了相關程序保障之最

然而居留地位的不穩定性，會同時影響到外國人工作的機會與條件，但純粹程序保障卻無從對這些影響加以檢視。例如將工作能力與居留資格完全連動的設計，往往會使勞動過程中的傷病風險完全由勞動者承擔（如暫時傷病導致失業，連帶失去居留資格），或使雇主之於受僱者享有不成比例的支配力。是以，以移工為對象的諸公約，對於國家剝奪居留的事由，較諸經社文公約，提供若干實質的保護，不過，其保護對象範圍相對狹窄；且不意外的，外國人本身的法律身分必須越穩固，才較有可能獲益於實質保障。

以移工公約為例，其對得自由選擇工作的有證移工（例如我國的白領移工、或已獲永久居留資格的外國人），規定就業國不得僅因工作終止，而視其為無證、令其喪失居留許可，至少須允許他們有足夠時間謀職，在享有失業津貼的期間內更不得撤銷其居留⁹³。相對地，對於不得自由選擇工作的移工（請注意，這個分類也代表移工公約容許就業國，在一定條件下剝奪移工選擇工作的自由），移工公約雖類似地規定移工之居留許可，不得僅因工作終止而喪失，但若該特定工作是外國人入境與居留的條件，則不在此限⁹⁴。也就是說，只要就業國事先將持續從事特定工作，與入境、居留的條件綁在一起（正如在暫時性移工制度中所常見的），則移工公約並未提供移工在失去工作時，抵抗國家驅逐的權利。

相較於移工公約，ILO第143及97號公約都有更實質的發展。首先，第143號公約第8條第1項則可說是對於國家驅逐移工之權力，

低要求，但這些保障的前提正是肯定國家的境管權力，理由書指出「外國人並無入境我國之權利」，而為了確保無權入境、居留之外國人確實被驅逐出境而暫時收容外國人，是「國家主權之行使」。司法院釋字第708號解釋解釋理由書第3段。

⁹³ 移工公約第49條第2項。

⁹⁴ 移工公約第20條第2項也有類似的規定，要求不得僅因移工未履行其聘僱契約上的義務而被撤銷居留許可、聘僱許可或被驅逐出境，可是若該義務是入境條件即不在此限。第20條雖同時適用於有證與無證移工，但是無證移工如何援引此一權利，殊難想像。

最為實質的拘束。其未區分移工有無自由選擇工作權利，凡合法居留之移工，其居住或工作許可，不得僅因失業而遭撤銷，且受就業安全、失業給付之平等對待。這是在避免雇主得藉由終止僱傭，改變移工的移民地位，從而剝削移工的勞力⁹⁵。本項規定因此直指移工脆弱處境的核心之一，使僱傭契約與居留資格部分地分離。不過，它主要保障移工在居留屆期前不因失業而失去居留資格⁹⁶，國家仍可要求移工在居留屆期時離境。但這已經是對國家之居留掌控權力最具實質拘束的規範。

再者，ILO第97號公約第5條與第8條之實踐亦值得注意：ILO專家委員會從第97號公約第5條有關就業國應在移工移徙及抵達的過程，對移工提供適當醫療的義務推導出，就業國不得以不影響就業的醫療理由（如HIV之感染），拒絕移工入境或遣返移工，否則構成歧視⁹⁷。又第8條禁止國家對於獲准永久居留的移工及其家屬，在其無工作能力時，將之遣返。ILO專家委員會還是強調第8條不觸及國家決定是否許可移工入境的權力，其重點是保障已經在境內的永久移工之居留安定性，避免移工在需要依靠社會扶助時，連帶失去居留的資格⁹⁸。不過這個規定只適用於合法入境、且在入境

95 RYSZARD CHOLEWINSKI, *MIGRANT WORKERS IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: THEIR PROTECTION IN COUNTRIES OF EMPLOYMENT* 130 (1997).

96 *Supra* note 88, ¶ 424.

97 E.g. “the Committee recalls that refusal of entry or repatriation on the grounds that the worker concerned is suffering from an infection or **illness of any kind which has no effect on the task** for which the worker has been recruited, constitutes an unacceptable form of discrimination” (emphasis added). ILO, *Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014): Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)- Belize (Ratification: 1983)*, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3126877; ILO, *Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009): Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1951)*, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2300593. 第97號公約此處相關的規定會牽涉到以下肆、二部分所談之移工健康檢查規範。

98 “The Committee recalls that Article 8 does not concern the admission or entry of

後發生傷病而無法工作的永久移工，對於無證移工或有證的暫時性移工均不適用⁹⁹。

這些例子都顯示一個相對穩定的居留資格，對於適度分散移工所可能遭遇到的傷病風險，是重要的。然而，ILO相對於聯合國人權公約系統，對外國人居留提供較為實質保障的取徑，是否會影響經社文公約與移工公約未來的實務發展，尚待觀察。

（三）正當或明文之差別待遇

最後，在移工居留期間，國家對於外國人之就業機會與工作權利，一般會基於移民法上不同之分類，給予工作權利上之差別待遇，不只是外國人與本國人之間有所差距，不同身分的外國人之間也可能有所不同。而這些差別待遇，可能藉由經社文公約第4條加以正當化¹⁰⁰。再者，出於內國之經濟考量而優先保留給本國人就業機會，鑑於國民間彼此社會連帶的關係，以及上述移民管制用以保護內國勞動市場的歷史，通常會被視為正當的差別待遇¹⁰¹。

除了以上述一般性正當化差別待遇的方法外，各移工相關公約

workers to Trinidad and Tobago but the maintenance of the right of migrant workers who have already been admitted on a permanent basis to continue to reside in the country in the event of incapacity for work. It wishes to point out that **security of residence of permanent workers** is one of the most important provisions of the Convention. Where this right is not effectively applied, permanent resident migrants find themselves living under the constant threat of repatriation” (emphasis added). ILO *Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009): Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)- Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)*, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2300701.

99 CHETAIL, *supra* note 66, at 203-04.

100 SAUL, KINLEY & MOWBRAY, *supra* note 23, at 316.

第4條規定國家對於公約權利，「僅得加以法律明定之限制，又其所定限制以與此類權利之性質不相抵觸為準，且加以限制之唯一目的應在增進民主社會之公共福利」。

101 *Id.* at 316; Lu, *supra* note 51, at 72.

也明文容許一部分對移工權利的差別對待，二個重要的例子是職業自由與就業安全：

首先，許多國家限制移工選擇工作的自由，並透過居留的控制加以執行，即把為特定雇主工作，綁定為移工入境及持續合法居留的許可條件。而此種對於進入職場與選擇職業之自由的剝奪，在一定條件下為保護移工之諸公約所允許，特別是針對暫時性移工。ILO第143號公約第14條容許針對居留期間在二年以下之移工，剝奪其選擇職業之自由；對於所有移工，亦得為促進就業國利益之必要，禁止其選擇某些特定的行業。移工公約第52條也有類似規定，且較諸第143號公約規定，對暫時性移工之職業限制更強。在移工公約之下，所有移工得因就業國之需要，依法限制其從事某些類型的工作，針對就業許可有時間限制之移工（例如暫時性移工），則可剝奪其選擇職業之自由二年；而若是為了保障本國人就業，更得剝奪其職業自由達五年。

儘管以上容許就業國在一定期間內剝奪或限制職業自由的條款，已提供就業國相當政策彈性，但現實上僅得在二年或五年期間予以限制的規定，仍遭到廣泛違反¹⁰²，許多國家認為暫時性移工，根本與職業自由的概念不相干¹⁰³。因此在多大程度上，移工能夠在實務上得益於平等的職業自由保障，是可疑的¹⁰⁴。

再者，有關移工失業時就業安全保障的差別待遇，移工公約容許國家針對特殊類別的移工，排除許多與就業安全有關之權利。例如「項目勞工」(project-tied worker)，指專為完成特定工作項目而聘用的移工¹⁰⁵，移工公約第61條不保障項目勞工在解雇、失業救

¹⁰² CEACR, *supra* note 88, ¶ 359.

¹⁰³ *Id.* ¶ 355.

¹⁰⁴ Ryan & Mantouvalou, *supra* note 63, at 200.

¹⁰⁵ 定義於移工公約第2條第2項第(g)款。

濟、就業服務、職業訓練、社會安全保障、社會住宅等方面之權利。又例如移工公約針對「特定雇用勞工」(specified-employment workers)——其中之一指雇主聘用來完成期間特定的短期工作，而在許可工作期間屆至或受聘任務完成後，必須離境的移工，如臺灣目前的藍領客工屬之¹⁰⁶，於第62條容許其失業時不受就業服務之平等待遇保障。注意這與ILO第143號公約第8條第2項，為合法居留移工提供包括轉業、失業救濟及職業訓練之平等保障，形成鮮明對比。

(四) 小結：平等保護規範的整合與跨越

前揭第一節指出，經社文公約與移工保護諸公約的發展，確立一般性對外國人勞動權利上的平等保護，但在本節則進一步指出，主權國家運用國境管制技術，對本國人與外國人（乃至不同類型的外國人）的工作權予以差別待遇。此二層面不無緊張關係，而總結迄今實踐，本文指出宜以「就業權利」與「勞動條件權利」對比的架構觀察，平等保護和移工雙重身分間之關係：

一方面，人權法對於國家限制外國人**就業上的權利**，相對寬鬆，尤其當權利之剝奪或限制，來自於國家對外國人之入境與居留所設定的條件時，人權法幾乎不介入。例如為經濟政策考量而將入境與居留條件設定為外國人不能從事哪些工作，乃至只能從事哪些工作，就業機會的平等保護對外國人而言無甚實益——在經社文公約下可能會被認定為是對外國人就業機會客觀合理之差別待遇，而移工公約下則明文允許（有期限地）對就業自由的剝奪。可以說，在這個領域內，外國人國境管制邏輯壓制勞工保護的邏輯，移工的雙重身分中，外國人身分重於其勞工身分。

106 定義於移工公約第2條第2項第(f)款。惟臺灣的暫時性藍領移工，表面上雖符合(f)款，實則已失「暫時」特質，所填補的勞力需求亦是長期需求，相關說明詳以下肆、一。

但他方面，外國人入境後，**勞動條件上的權利**則受到較高程度的保護——越是與居留條件無關的個人或集體勞動權利，若因國籍或移民法律地位而遭到差別待遇，越有可能被視為違反人權法之平等保護。例如工作環境的安全衛生或工資待遇，若存在基於國籍或法律地位的差別待遇通常顯得可疑。再者，外國人居留的法律地位越穩固，越易受到人權法上更周全的工作權利平等保護，例如因永久居留或依親而有求職權利的外國人，其法律地位較為穩固，通常對他們任何就業條件與工作條件上的差別待遇，都可能被視為違反就業平等，這點也反映在我國行政實務上（詳以上一、(三)）。是以在勞動條件權利的領域內，人權法規定與實踐傾向支持勞工保護的邏輯壓制外國入境管的邏輯，移工之雙重身分中，**勞工的身分重於其外國人的身分**。

由此架構觀之，人權法所不易著力的灰色地帶，即是國家透過對於入境、居留、遣返條件的設定，間接影響勞動條件的權利——而暫時性移工制度的主要制度特徵，卻往往處在這個灰色地帶中。在這裡，移工的勞工身分與外國人身分交纏不清，其工作條件未必直接受到勞動規範明文的限制，但因受限於居留條件，以及國境管控所造成的各層面不自由，而在勞動市場中處於脆弱被動的地位。此時人權法究竟應著重在對於國境措施的退讓，或是對於平等勞動條件的保護，乃有內在緊張。

然而，這個內在的緊張關係未必不能跨越，本文認為人權法迄今的實踐仍提供了重要的洞見。首先，在這個交錯領域裡，勞動保護與國境管控有彼此權衡之需求，並按個案脈絡化判斷。ILO專家委員會曾有啟發性地述及：使移工處於極端脆弱、勞雇權力極不均等的僱傭系統，構成對移工的歧視¹⁰⁷。而這點出了利害權衡可能

¹⁰⁷ ILC, *supra* note 58, ¶ 779. “The Committee considers that where a system of employment of migrant workers places those workers in a particularly vulnerable

的目標、方法與考量，亦即以整體性的觀點，判斷國境管控對整體勞動條件負面影響的加總，是否已經導致歧視性僱傭系統、累積成極端權力不均的壓迫性僱傭關係。

再者，許多人權法實踐顯示，越是確保勞動條件獨立於入境居留管制的影響、越是使勞工身分與外國人身分分離，越有可能避免歧視性僱傭系統的發生。例如：不只一個聯合國人權公約的監管機構指出，國家沒有義務給予外國人工作許可，惟一旦給予許可，就不得對其工作權利予以差別待遇¹⁰⁸。又例如美洲人權法院2003年針對非無證移工勞動條件的決定，詳細地說明勞動條件應與外國人身分分開評價：法院首先指出反歧視及法律前之平等，已具強行法（*jus cogens*）的性質¹⁰⁹，「因為整個國內與國際公共秩序均奠基其上，是貫穿所有法律的基本原則」¹¹⁰。而基於平等之規範重要性，法院繼而認定無論人的移民地位如何，勞動權益乃是基於勞工的身份而生，不得基於居留不合法而予以剝奪¹¹¹：「就業國與就業國內之私人，並無雇用無證移工的義務，可以避免與無證移工締結僱傭關係。但是一旦無證移工進入僱傭關係，他們便擁有對應於其勞工

position and provides employers with the opportunity to exert disproportionate power over them, this could result in discrimination based on the grounds of the Convention [No. 111]”.

¹⁰⁸ E.g., CESCR, *Concluding Observations: Portugal (Macau)*, ¶¶ 18-19, UN Doc. A/57/18 (Dec. 1, 2000); Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *Concluding Observations: Denmark*, ¶ 120, UN Doc. E/C.12/1/Add.15 (May 20, 1997). 這裡所涉及的甚至至求職與參加職業訓練的權利。

¹⁰⁹ *Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants*, Advisory Opinion OC-18/03, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 18, ¶¶ 97-110 (Sept. 17, 2003). 美洲人權法院在此尤其是指種族歧視之禁止。就種族歧視禁止屬於強行法範疇，亦可參，JAMES CRAWFORD, *THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION'S ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY: INTRODUCTION, TEXT AND COMMENTARIES* 188 (2002); Sandesh Sivakumaran, *Impact on the Structure of International Obligations*, in *THE IMPACT OF HUMAN RIGHTS LAW ON GENERAL INTERNATIONAL LAW* 133, 145 (Menno T. Kamminga & Martin Scheinin eds., 2009).

¹¹⁰ Inter-Am. Ct. H.R., *supra* note 109, ¶ 101.

¹¹¹ *Id.* ¶ 133.

身分的勞動權利，這些權利不得因其非正規的法律地位而遭到差別對待」¹¹²。國家因此有義務避免私人雇主歧視無證移工之勞動權利¹¹³，例如給予較低的工資。

綜言之，盡可能令勞工身分與外國人身分二者領域分離，是目前人權法對移工所提供的最佳原則。領域分離不代表具體做法上放棄國境管制的目的，而是必須將國境管控對於勞動權利的影響納入考量，並確保其整體而言不構成歧視性的僱傭系統。

最後，我們亦可從人權法的實踐中觀察到二點侷限。首先，對移工的一般性勞動與平等保護，即便是以移工為對象的公約，絕大多數的規定與實踐並不問外國人的類別、不分移工是暫時性移工、或具有永久居留資格之移工¹¹⁴，這看似使暫時性移工所受之保護水準，與具有永久身分的移工相同，但卻也使人權法不夠重視時間因素對於勞動地位和待遇的負面影響，疏於發展更細緻的工具去應對暫時性移工制度各種彈性化勞力（flexibilization of labour）的設計¹¹⁵。因此當暫時性移工制度，在國際上越來越常被用來提供極端

112 *Id.* ¶¶ 135-136.

113 *Id.* ¶ 173(9).

CESCR在審查時也表達過類似無證移工應受平等待遇的觀點：CESCR, *Concluding Observations: Japan*, ¶ 21, UN Doc. E/C. 12/JPN/C/3 (June 10, 2013).

114 Ryszard Cholewinski, *The Human and Labor Rights of Migrants: Visions of Equality*, 22 GEO. IMMIGR. L.J. 177, 202 (2007); see also ILO, *Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - North Macedonia (Ratification: 1991)*, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3087344. “The Committee recalls that Article 10 of the Convention [No. 143] requires ratifying states to declare and implement a national policy designed to promote equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, of social security, of trade union and cultural rights and of individual and collective freedoms of persons who are as migrants or as members of their families lawfully in the territory, and that this policy should cover both permanent or temporary migrant workers”.

115 Ryszard Cholewinski, *International Labour Law and the Protection of Migrant Workers: Revitalizing the Agenda in the Era of Globalization*, in GLOBALIZATION

彈性勞力¹¹⁶，便成為不易應對的挑戰¹¹⁷。

第二點，防堵無證移工通常是移工相關各公約的目標¹¹⁸。此目標本無可厚非，因為無證的狀態容易讓移工陷入剝削情境，故減少無證移工有助於間接達成保護移工的目的、避免人口販運與現代奴工。可是無證移工的產生，很多時候來自嚴峻的國境管制措施，使移工易於失去有證身分；且防堵無證移工的措施，在現實上可能再度加深無證移工的污名。所以防制無證移工目標的實現，假如不是藉由合理化國境管制的安排、或給予無證移工合法化的管道¹¹⁹，而是透過緊縮無證移工的生存空間來達成，那麼可以預期的是，國家必然更加強調國境管制的貫徹，從而使國境管制的優先性更易凌駕於移工勞動保護的考量——也就更可能惡化有證及無證移工的地位。這也表示，若國境的執行，不考量其在勞動領域的效應，則對諸公約而言，反而易導致悖反於其保護目的的弔詭。

以下第參部分，將進入臺灣的暫時性移工制度，以其政策背景和國境管控技術，解析制度運作的邏輯，並作為第肆部分的基礎。第肆部分則透過4個「以國境管制技術影響勞動條件」的面向，來顯示移工的外國人身分，是如何與其勞工身分交纏不清，而前者始終壓制後者，也從前述人權法所提供的資源出發，反思若干替代措施的可能。

AND THE FUTURE OF LABOUR LAW 409, 418-19 (John D. R. Craig & S. Michael Lynk eds., 2006); Judy Fudge, *Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of International Rights for Migrant Workers*, 34 COMP. LAB. L. POL'Y J. 95, 123 (2012).

¹¹⁶ Olney & Cholewinski, *supra* note 64, at 277.

¹¹⁷ Cholewinski, *supra* note 115, at 417.

¹¹⁸ CHETAIL, *supra* note 66, at 206.

¹¹⁹ 例如移工公約第68條所規定的方式。

參、臺灣「暫時性移工制度」之設立與運作邏輯

第參部分的前半會回顧1980年代臺灣引進藍領移工的背景、社會顧慮與政策目標，並指出移工制度預設能滿足其政策目標的勞動力，本不利於平等保護的開展。後半則藉由鳥瞰移工跨國流動從入境到出境的管制流程，一方面解釋各階段的管制方式在回應哪些政策考量，另一方面也顯示國境管控的作用，係滲透在移工整個跨國移動的歷程。

一、制度背景與政策目標

臺灣的移工制度正式從1992年開始，而回顧移工政策進入臺灣前的背景與政策目標，有助於理解整體移工制度之內在邏輯，因為臺灣外勞制度的形塑，相當程度反映了1980年代相關辯論的語境。當時臺灣產業界開始發出缺工的呼聲，對營建與製造業造成衝擊¹²⁰，官方發佈數字顯示缺工高達21萬名¹²¹，而產業界以撤資本土、改投資海外相脅，一直希望能引進勞力來應對勞力缺口¹²²。同時期也出現逾期滯留於臺的外國人（所謂「黑工」）已成嚴重社會問題之說，乃有政策引導與管理的呼籲，而引入暫時性移工則被視為是維持經濟發展動能，同時將黑工導入正軌的解方¹²³。

然而另一方面，同時期亦有許多引進移工是禍不是福的論述：移工被說成易於散播疾病、擾亂社會治安、從事性交易的人群，因此

120 張威儀，臺灣勞動體制的剝削本質——歷史制度主義的觀點，國立中山大學政治學研究所碩士論文，頁54（2012年）。

121 立法院公報，80卷11期，頁74，勞工委員會職業訓練局陳聰勝局長發言（1990年）。

122 曾熾芬，引進外籍勞工的國族政治，臺灣社會學刊，32期，頁16-17（2004年）。

123 于宗先、王金利，臺灣人口變動與經濟發展，頁200（2009年）。實則「黑工」數量的情況難以掌握，在臺灣引進移工的前夕，官方評估認為約有2萬名「黑工」在臺。立法院公報，80卷11期，頁76，法務部翟宗泉次長發言（1990年）。

引進移工會造成某些社會成本，傳染病肆虐，造成公共衛生上的負擔¹²⁴；提高犯罪率，造成治安上的隱憂；又迥異於國人，易造成族群衝突等¹²⁵。此外，引進低階的廉價勞動力在經濟層面則會減緩產業升級的進度、提高弱勢勞工（如原住民）的失業率¹²⁶、惡化國人的勞動條件、擴大貧富差距、外來的人口也會增加公共建設跟社會福利制度的負擔¹²⁷。這些論述，正如同前述在19世紀末的移民管控興起的歷程所見，既是對勞動處境和階級衝突惡化的真誠憂慮，但也不時夾雜著種族/國族優越的潛流。

值得注意的是，缺工聲高漲的1980年代，也同時是臺灣的勞動規範轉趨嚴格而勞工運動開始湧動的時代，勞動基準法於1984年開始適用於製造業，在此之前，製造業習慣於極彈性的勞動力，謝國雄勞動社會學的經典之作描繪出一副彼時臺灣沒有底薪、計件制受到廣泛採用、亦欠缺基本工資、遣散費和有薪假保障的勞動景象¹²⁸。1987年臺灣解嚴，勞動意識的升高與勞工運動的發展，被視

124 兩則事例可以說明彼時政策制訂者與學界泛泛將移工與疾病傳染劃上等號的態度，一則是1991年時任衛生署長的張博雅於1991年11月5日在民生報發表對抗愛滋的公開信，指出愛滋病在臺灣「暗潮洶湧，蓄勢待發」，這是因為「當今社會，工商發達，旅遊盛行，道德淪喪，色情氾濫，外籍勞工湧入，毒品走私猖獗」，「如果我們還不起戒心，那麼……國內多數人將難以逃過愛滋病肆虐的浩劫」（粗體為本文所強調）。轉引自黃道明著，陳柏旭譯，台灣國家愛滋教育之國族身體形構與情感政治：以世界愛滋病日為線索，文化研究，15期，頁15（2012年）。二則是張昌吉，外籍勞工對經濟、社會、政治層面影響之分析，政大勞動學報，12期，頁271-272（2002年），主張外籍勞工對社會秩序有影響，因為他們的心理狀態不穩定；外籍勞工的引進對臺灣防治肺結核、登革熱及愛滋有負面效應，張文對於愛滋病部分的理據是因為認為在泰國有比較高的盛行率，而臺灣當時引進比較多的泰國移工。

125 藍佩嘉，跨國灰姑娘：當東南亞幫傭遇上台灣新富家庭，頁98-102（2008年）。

126 于宗先、王金利（註123），頁201。

127 王素彎、吳惠林，外籍勞工在臺灣的趨勢、經濟關聯與政策，人口學刊，22期，頁49、60（2001年）。

128 謝國雄，勞動力是什麼樣的商品？計件制與台灣勞動者主體性之形塑，台灣社會研究季刊，17期，頁83-119（1994年）。謝文指出，在計件制普遍存在的製造業環境中，儘管法定的勞動條件保障低落，但是勞工接受這樣的狀況，

為對投資與經濟發展的威脅¹²⁹。故缺工的呼聲所指的，不只是勞動力的匱乏，更是在要求彈性、柔順、低廉的勞動力。外籍勞工乃看似是此種特定勞動力需求的合宜解方。

1989年以避免國家重大建設進度落後為由，臺灣開始嘗試性地引進暫時性的藍領移工，以因應公共建設的勞動需求¹³⁰。政府訂定帶有實驗性質的一次性行政規則「十四項重要建設工程人力需求因應措施方案」，容許十四項重大建設的包商，引進20歲以上的泰國成年男性以補充營造業勞工。因應社會上有關疾病傳染、治安威脅與人口增加等疑慮，移民控管設定嚴苛條件，除了要求移工須「身心健康、無不良紀錄及嗜好，並應檢具工作專長及健康證明書」外¹³¹，移工會被遣返回國的理由包括「攜眷來華」、「受僱期間結婚」、「檢出HIV陽性帶原」、「罹病未能在一個月內治癒」、「喪失工作能力」、「有違公序良俗」¹³²。該方案的聘僱許可僅有1年效期，屆期得展延一次，即最多可以在臺工作2年¹³³。這些嚴格的規定隨後並成為臺灣正式移工制度的雛形。

因為他們有著「小老闆意識」：想做就做、不想做就不要做，而不做不賺是天經地義的道理。勞工自認是「獨立」的，不靠老闆照顧其生計。計件制將超級彈性的勞動型態根植於1990年臺灣工人的集體意識中。實則此種所謂獨立與彈性，與今日零工經濟所標榜者若合符節。

129 張威儀（註120），頁74；曾熾芬（註122），頁33。

在解嚴及民主化之前，國民黨政府藉由滲透工會、製造工會活動的法律阻礙、將工會納入其政治網絡中，嚴密控制工會及勞工運動，彭雪玉，國民黨政府勞動控制體制之探討：1949-1987年間歷史與結構的因素，思與言：人文與社會科學雜誌，44卷3期，頁209-215（2006年）。

130 劉梅君，「廉價外勞」論述的政治經濟學批判，台灣社會研究季刊，38期，頁63（2000年）。

131 十四項重要建設工程人力需求因應措施方案，第4點第（5）款，臺灣省政府公報，春字九期，頁10（1991年），<https://catalog.digitalarchives.tw/item/00/12/ec/4f.html>（最後瀏覽日：2019年9月12日）。

132 十四項重要建設工程人力需求因應措施方案第4點第（18）款。

133 十四項重要建設工程人力需求因應措施方案第4點第（8）款。

在上述背景之下，官方提出移工制度4個主要政策目標，「外勞引進不得有礙產業的升級」、「不得使外勞成為變相的移民」、「不使外勞引進帶來治安和衛生保健問題」、「引進外勞應採補充性原則」¹³⁴。這些政策目標顯然在回應當時社會有關引進跨國勞動力的種種質疑，而移工保障在這個階段還不見諸政策視野裡¹³⁵。所謂不能妨礙產業升級，指的是移工理論上只能作為暫時的緩解、不能長久依賴，廠商仍應改善製程或以機械取代人力。補充性原則指的是移工須確實進入勞動力短缺的產業部門中，不應與本國勞工競爭工作機會，是以移工所進入的勞動市場必須是本國勞工沒有意願進入的次級勞動市場¹³⁶。至於不得變相移民，雖然可能反映對「低端」勞動人口和特定國家外國人的排拒，但也出於當時對於人口密度的憂慮，以及降低再生產成本的經濟考慮：讓移工維持在沒有穩固法律地位的狀態有助便於彈性運用人力，並避免分擔家庭相關的人事成本。至於治安與衛生保健的考量，不諱言或有主觀偏見與臆測成分，但是維持社會治安與防疫無論如何仍是現代國家固有的任務。

因此這些政策論述，暫不論其是否隱藏排外的種族動機，抽象來看，特別是產業升級與補充性原則，並無不正當可言。然而在臺灣脈絡下，當其轉譯成細部制度設計時，為了確定移工只能進入到受認可的勞動力短缺之處任職，乃設計了層層移工員額控制的機

134 這幾個政策目標係於趙守博擔任勞工委員會主委時所提出，參趙守博，外勞政策的調整要確實對我國有利也應顧及公平與正義，國政分析，2012年10月22日，<https://www.npf.org.tw/3/11510>（最後瀏覽日：2019年8月11日）。

135 從文獻耙梳中，移工的權利保障較正式地成為官方的政策論述是2001年後行政院勞工委員會所推出之外籍勞工（後改稱為移工）權益報告書，參註2。

136 次要（secondary）勞動市場是相對於主要（primary）勞動市場而言，此概念來自二元制的勞動市場分割理論，主張勞動市場是由彼此區隔的次市場（sub-markets）組成，其中主要勞動市場通常是高所得、工作穩定、勞動條件好、有培訓跟晉升的機會；反之，次要勞動市場則收入低、工作不穩定、勞動條件低落、沒有培訓跟晉升的機會。而主要與次要勞動市場之間是封閉的，少有流動。Michael L. Wachter, *Primary and Secondary Labor Markets: A Critique of the Dual Approach*, 1974 BROOK. PAP. ECON. ACT. 637, 638 (1974).

制；為了確保不要與本國勞工競爭，必須禁止他們進入勞動市場成為自由勞動力；為了促使產業不要長久依賴、也避免移工留下，乃設計頻繁輪替且隨時可以請人走路的短期居留與定期僱傭制度；也因為預設只有對於本國人民沒有吸引力的工作才僱請移工，因此勞動條件通常低薪，且對體力與耐力有著高度要求。而能夠達成這種政策目標下的特定勞動力，必須是可以透過國境管控措施去篩選、限制、與隨時要求離境的暫時外國勞動力；唯有能夠被加諸本國勞工不可能被加諸之限制的客工，能夠負擔起這些政策要求。

因此可以說，臺灣的移工制度預設引進的勞動力樣貌，對平等勞動待遇落實是不太友善的起點。而此種不友善，在特定案例裡，隨法院與行政實務而變本加厲。就業服務法於1992年通過正式制度化移工引進時，將上述大部分政策寫進法律規定中¹³⁷。其中，補充性原則，本意係在避免外國人與國人競爭工作機會，但某些實務判決卻將之解釋為移工之勞動待遇應劣後於國人，加劇了客工制度與平等勞動條件間的互斥。例如，最高法院認為當雇主因為不景氣需要解雇本國勞工時，若未詢問其是否願意以合理的薪資條件從事移工正在從事的職位，便予以資遣，即與法不合¹³⁸。也就是說，若本國勞工表示願意轉職，雇主必須解雇移工。移工在這個解釋下，扮演了經濟景氣榮枯的緩衝角色，受法律要求，其職業上的穩定性必須劣後於本國勞工。又如，行政院勞工委員會之函釋表示，在經濟不景氣時期，雇主若給付移工薪資但積欠本國勞工薪資，便是妨礙本國人的就業機會，法律效果上可能導致未來的移工申請遭到拒

137 當時就業服務法第41條，今第42條：「為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定。」唯一未寫入法條的是「禁止變相移民」，但這不表示官方禁止藍領移工移民一事有任何退讓。相反地，綜觀立法過程，確保藍領移工不致永久移居一直都是考量。因此第42條未提及移民限制更可能係因就業服務法也規範白領移工，而對白領移工政策上並無禁止移民的限制。這裡法條與政策宣示之間些微但刻意的文字差異，愈突顯高階與低階移工之間的待遇落差。

138 最高法院94年度台上字第2339號民事判決。

絕¹³⁹。此一實務見解將工資待遇問題，轉化為工作機會分配的問題，凸顯出工作機會的分配，與勞動條件的維持之間，在實際運作中是流動的，而移工的外國人身分，會隨時架空其勞工身分中像工資這麼基本的權利。

實則，移工對雇主之工資債權，與本國勞工對雇主之工資債權之間，根本不應有所先後，主管機關以補充性原則來排序債權先後，不僅欠缺民法與勞動法上的基礎，有悖於人權法上移工所享有之平等勞動條件，亦與補充性原則的目標矛盾：因為愈是希望本地勞力不被外國勞力取代，就愈應當維持本地與外國勞動力間條件的平等，以免移工因權利保障薄弱更形價廉，而加深雇主對外國勞動力之依賴¹⁴⁰。

臺灣的藍領移工制度，經過30餘年之發展，已從實驗性質的單次政策，進展成為規模龐大的人力輸入產業。截至2019年9月止，在臺移工人數超過714,000人，約佔我國就業人口的6%¹⁴¹，已是臺灣勞動力所不可或缺的組成部分。下一節則說明藍領移工如何通過國境管制來到臺灣。

二、移工跨國流動之文書控管

上一節所述之各項移工政策，具體作法係透過各種移民文件與工作許可的發放予以落實，包括招募許可、聘僱許可、入境許可、外僑居留證、生活計畫、健康檢查等。行政文書控管是很好的角

139 參勞工委員會2008年12月6日勞職許字第0970503915號函。

140 Martin Ruhs, *Immigration and Labour Market Protectionism: Protecting Local Workers' Preferential Access to the National Labour Market*, in *MIGRANTS AT WORK: IMMIGRATION AND VULNERABILITY IN LABOUR LAW* 60, 64-68 (Cathryn Costello & Mark Freedland eds., 2014).

141 勞動部，勞動統計月報，<https://www.mol.gov.tw/statistics/2452/2453/%E5%8B%9E%E5%8B%95%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%9C%88%E5%A0%B1/>（最後瀏覽日：2019年10月3日）。

度，去觀察國家權力如何透過正式文件，對外國人進行管制，並有助讀者鳥瞰跨國移動的流程¹⁴²。

這些文書管制頗為繁瑣——此毋寧反映了跨國流動所面對的行政與經濟成本。以下按跨國流動歷程，分三部分說明：雇主之招募許可、移工之入境與居留許可、移工之期滿離境。每個階段各有觀察重點：在雇主之招募部分，管制在確認缺工與移工數量的分配與控管，但制度設計未必能確保與缺工之緊密關聯。而對移工之入境許可、居留的各項要求，則帶入前述有關勞力需求、健康與治安問題的政策考量，注意即便是著眼於移工保護的文件要求，仍充斥不友善設計，並認可移工在遷徙過程中所承受的經濟負擔。最後有關移工居留與離境的制度設定，顯示移工的每個配額從入境到出境均須一貫受到掌控。

（一）雇主之招募許可

藍領移工之引進採取「限業限量」政策，亦即僅有法定行業、或主管機關依法指定的行業¹⁴³中的特定職務，可以聘僱特定數量之移工。現行准予雇用藍領外籍移工之行業包括家庭或看護機構之看護、符合3K（髒污、危險、辛苦）¹⁴⁴製程的製造業、專案核定的

¹⁴² 不過這個角度亦有侷限，最重要的限制是私人仲介隱而不顯。因臺灣的移工制度原則上要求藍領移工必須「境外招募聘僱」（雇主聘僱外國人許可及管理辦法第25條第2項）。這使得未謀面的勞雇雙方需仰賴第三方媒合，如果國家不負擔起媒合的角色，移工與雇主只得透過私人仲介締結雇傭契約。而在私人仲介壟斷工作機會、移工資訊不對等、且跨國收費不透明的情況下，仲介對移工權益影響頗大。可是從正式行政流程去觀察，就看不到仲介於跨國流動中的角色。讀者可將下述雇主的任務及權力，理解為在實務上透過仲介業者代理執行，但有關三方關係對移工勞動地位的影響，仍待另文討論。

¹⁴³ 就業服務法第46條第8至11款。

¹⁴⁴ 3K用語，源自日文的Kitanai（汚い）、kiken（危險）與kitsui（きつい）。英文則是用3D來指稱（即dirty、dangerous、demanding）。這個用法可以參考例如Yasuo Kuwahara, *Migrant Workers in the Post-War History of Japan*, 2(4) JAPAN LAB. REV. 25, 25-47 (2005)。

營建工程、海洋漁撈工與屠宰工¹⁴⁵、以及從2019年開始試辦的酪農及農業外展工¹⁴⁶。而每一個行業又個別設定雇主需具備之條件，例如家庭看護，必須照顧者的年齡達到標準、依賴程度通過評估¹⁴⁷。又例如製造業法令層面只開放「特殊製程（3K）」或「特殊時程」（三班制）工作，並按條件環境之艱困程度，設定得聘僱移工之比例¹⁴⁸。不過3K產業的困難危險，是否一定反映缺工程度，是需要不斷檢討的，因為缺工還受到技術跟薪資條件的影響。又近年移工配額也被用作獎勵投資的工具，例如自由貿易港區內的製造業可以雇用達40%的移工¹⁴⁹，並且可以先聘移工，事後再補足本國勞工的聘僱數量。然一旦作為促進投資的工具，移工引進即非謹守避免取代本國勞力的目標。

雇主得雇用移工之資格，設計上除了用以確保移工引進不排擠國民之就業外，亦有可能作為引導雇主切實遵循勞動規範的誘因。例如現行規定欲招聘產業移工的雇主，需有遵守勞動法令的良好紀錄，例如依法提撥勞動退休金，定期召開勞資會議，結清勞工保險

145 勞動部勞動力發展署，外籍勞工工作資格及規定，<https://www.wda.gov.tw/NewsFAQ.aspx?n=9C9CC6640661FEBA&sms=A1CA5B0D37C1A94B>（最後瀏覽日：2019年8月27日）。

146 行政院農業委員會，開放外國人從事乳牛飼育及外展農務服務 補充農業勞動力，https://www.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=agri&id=7762（最後瀏覽日：2019年8月27日）。

147 外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第22條。

148 特殊製程條例由經濟部工業局所指定例如「異常溫度作業」、「粉塵作業」、「有毒氣體作業」、「有機溶劑作業」、「化學處理」、「非自動化作業」，依其工作環境艱困程度分為ABCED五級，分別得聘僱移工的比例為10%、15%、20%、25%及35%。亦即A級產業得聘僱10%之移工，某雇主若有10名本國勞工，得聘僱一名外籍移工。按所雇之本地勞工比例計算配額的方式，對於規模較大的廠商，較為有利，商業規模愈小的雇主，愈不容易取得名額。由於移工政策會壓低移工薪資，因此可以聘僱移工對產業的人事成本有類似提供補助的效果，這也意味著規模大的事業會得到更多的補助。

149 外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第15條之7。

雇主所應負擔之保費及清償罰鍰，不得涉入勞資爭議事件或罷工，亦不得有事業緊縮之跡象¹⁵⁰。

雇主在聘僱移工之前，並須先以合理勞動條件在職業訓練所或報端招募本國勞工未果¹⁵¹。這是補充性原則在制度上的展現，惟亦易流於紙上作業。值得注意的是主管機關定期公告雇主招聘本國勞工所應符合之「合理勞動條件」薪資¹⁵²，通常都高過移工實際領取的法定基本薪資，這是官方對於本外勞工同工不同酬的認可。

(二) 移工之入境與居留許可

雇主獲得招募許可後，需在6個月內至特定國家招聘移工，否則許可即失效力¹⁵³，目前移工來源國限於印尼、菲律賓、越南及泰國¹⁵⁴。當雇主（透過仲介在當地）招聘到移工，移工欲申請簽證，必須有合格的健康檢查報告、行為良好證明（即證明無犯罪紀錄）、工作費用及工資切結書、簽妥之勞動契約、外國人知悉本法相關工作規定之切結書¹⁵⁵等，移工申請簽證並須按捺指紋，以查核過去有無違規¹⁵⁶。

¹⁵⁰ 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第12條。

¹⁵¹ 就業服務法第12條。

¹⁵² 參如勞動部2019年12月19日勞動發管字第1080517006號函。

¹⁵³ 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第25條第2項。

¹⁵⁴ 目前開放泰國、菲律賓、印尼、越南、馬來西亞與蒙古六國，但實際上馬來西亞與蒙古的移工數量很少，截至2019年8月底，馬來西亞籍的移工僅餘1人，蒙古0人。參勞動部，產業及社福移工人數按國籍及開放項目分，<https://statdb.mol.gov.tw/evta/JspProxy.aspx?sys=220&ym=10808&ytm=10808&kind=21&type=1&funid=wq1411&cycle=41&outmode=0&compmode=0&outkind=2&fldspc=0,29,&codspc0=0,8,&rdm=omh4c4bi>（最後瀏覽日：2019年9月25日）。

¹⁵⁵ 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第27條

¹⁵⁶ 外交部，外交部規劃僅針對東南亞來臺外勞申請簽證時採捺指紋，https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=95&sms=73&s=62972（最後瀏覽日：2021年1月25日）。再者，申請外僑居留證時亦需按捺指紋入，移民署，外籍移工專用居留案件申請表，頁2（2014年）（注意事項第2點）。

其中所謂「外國人知悉就業服務法相關工作規定切結書」¹⁵⁷，雖係為提高移工之法律認知，或許寓有保護之意，但行文充斥訓示語氣，著重提示工作許可能遭到廢止的各種狀況，例如不得連續曠職3日與雇主失去聯繫（即俗稱的「逃跑」，詳參以下肆、四）、不得竊取或侵佔工作場所之物品¹⁵⁸。類似地，「外國人入國工作費用及工資切結書」¹⁵⁹須經移工、仲介及雇主簽名後，在移工本國經該國主管機關驗證，其中載有移工在法令下得被收取之仲介費用、勞保健保費用、因跨國移動所借貸的債務與每月的薪資數額等，這是讓移工費用與權利義務關係透明化的嘗試，並保護移工使其瞭解薪資結構，但它同時在制度上承認移工必須負擔絕大多數的跨國移動所生之費用¹⁶⁰。又「切結」指的是當事人對一事承諾負責、承擔義務或拋棄權利之意，但移工之工資數額與不應被收取之費用，根本屬雇主與仲介的義務事項，移工如何「切結」令人不解¹⁶¹。種種用語欠妥，反映的是就業國對於藍領移工高高在上的姿態，於保護性的舉措亦不例外。

移工入境後需要立刻準備「外國人入國通報單」，通報當地主管機關進行檢查，以確保移工確實受僱於指定的雇主以及地址，查驗「外國人生活照顧服務計畫書」（詳下肆、四說明），及經外國人

157 勞動部2020年5月4日勞動發管字第10995937191號令，勞動部勞動力發展署，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&s=B474E7475B71811C（最後瀏覽日：2020年6月20日）。

158 各語言版本可於勞動部勞動力發展署網站獲得：勞動部勞動力發展署，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&s=B474E7475B71811C（最後瀏覽日：2020年6月20日）。

159 勞動部2020年1月6日勞動發管字第10805086231號令，勞動部勞動力發展署，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=7FAD35606C219599&sms=C61580640A6257EF&s=E409F138644D5E24（最後瀏覽日：2020年6月20日）。

160 但檯面下的費用並不會出現在切結書上，因此對於避免移工被超收費用的效果有待商榷。再者儘管入境前之勞動契約業經認證，但這並不妨礙入境後雙方「合意」修改契約降低薪資的可能。

161 此一批評論針對中文版，而例如英文版使用的是“affidavit”一詞，但移工同樣要對屬於雇主與仲介義務內之事項，保證其真實。

(三) 移工之居留屆期與離境

過去藍領移工居留與聘僱許可期滿，移工必須離境後再入境，2016年臺灣廢除居留與聘僱許可3年期滿最少須出國一日之要求¹⁷⁰，因此若聘僱許可將到期，而雇主有意繼續聘僱，雇主應於屆

170 參2016年10月21日修正前後之就業服務法第52條。修正理由可於立法院法律系統獲得，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?008F463B2D22000000000000000000000032000000007000000^03615107110900^0009B001001>（最後瀏覽日：2021年2月22日）。

滿前2至4個月內申請期滿續聘許可，雇主如無意續聘但移工有意繼續在臺工作，移工應申請期滿轉換雇主¹⁷¹。如契約在聘僱許可到期前中止，則必須先到地方主管機關辦理認證¹⁷²，以避免雇主以違反移工意願方式，逕將移工送到機場遣返、解約。移工期滿或提前離境後，雇主取得「外國人離境備查函」，始完成移工從入境到離境的程序，而得聘用下一位移工。

總之，移工入境的目的既然是受聘僱，因此其入境居留的許可與受聘工作的許可二者緊緊扣連，從申請入境到最後出境，必須全程符合入出境管制所設定的條件，包括身體的條件、工作地點內容、所在地點。而制度的原始設計是每一移工從境外聘僱入境後，佔用一個配額，原則上必須等到該名移工因故離境，例如死亡、許可屆期或廢止¹⁷³，同一個配額才會被騰空出來供下一移工使用，以此控制整體移工引進的數量。此一運作的邏輯自然須仰賴對移工自入境到出境行蹤的高度控制。

在說明了臺灣移工制度之政策背景、目標以及執行目標之移工入出境文書管制後，第肆部分則關注移工外國人身分所受之國境管制作用，如何具體影響其勞工身分所應享有之權益。

171 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第28條之2及28條之3。

172 雇主辦理與所聘僱第二類外國人終止聘僱關係之驗證程序第3條。地方主管機關須確認中止不違背移工的意願，或雇主有單方中止雇傭的理由，並查驗由雙方語言書寫，經雙方簽名的中止通知、與移工面談，確認薪資明細，確認雙方無爭議後發給認證。雇主若未取得認證，則移工提早離境後，無法聘用下一名移工遞補該缺額。

173 例外是移工行方不明時，依移工類別容許雇主在3個月或6個月後再度招聘，就業服務法第58條第1項。

肆、國境控管對移工勞動條件之效應

從上述跨國流動過程中，本文抽繹出4項管制措施，說明國境在勞動條件上的效應。它們並未窮盡客工制度的問題，但共通的是均與國家設定入境條件、控制外國人居留、分配工作機會的權力緊密連結，進而影響勞動條件。其所仰賴的「暫時性」（指不斷強制輪替，切分、縮短就業與居留之時間），與「異國性」（指不穩固的移民法律地位使其受制於國境無時不刻的監管，並處於可遣返（deportable）的狀態）法律技術，因為不可能適用於本國勞工之上，以致從傳統平等保護的操作角度，未必有可比較之群體，從而難以辨識出差別待遇，影響移工平等保護的功用。

一、強制定期契約：永久臨時工

藍領移工不得長期居留，是臺灣移工制度的核心政策之一¹⁷⁴。而移工的暫時性是透過定期之聘僱許可與居留許可（2016年之前尚有居留許可到期後強制出境）加以貫徹執行，連帶將移工僱傭契約，一律為定期契約¹⁷⁵。工作與居留兩者相互牽制，僱傭契約若因故提前終止，也會導致聘僱許可乃至居留許可之提前失效。

然而，暫時性其實是「法律虛構/擬制」（legal fiction），因為只有個別移工的時間是暫時的、廉價化的，但移工整體，則是勞動結構裡永久的一部份，提供雇主穩定供應的長期廉價勞動力¹⁷⁶。現代的客工制度大抵都有定期強制輪替的特徵，但暫時性的虛構，在

174 2018年底行政院通過新經濟移民法草案，考慮容許居留6年以上之藍領移工的申請永久居留的可能，但是後續發展仍需觀察。行政院，<https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/35b7ec85-9272-4850-a701-b183fc1104cf>（最後瀏覽日：2019年9月12日）。

175 就業服務法第46條第3項。

176 Ya-Wen Yang, Towards Democratic Citizenship for Temporary Migrant Workers: A Non-domination Approach, 64-65, 242 (2019) (unpublished Ph.D. dissertation, SOAS University of London) (on file with author).

臺灣的客工制度的例子上很明顯，因為臺灣移工之累計得居留期間相當不「暫時」¹⁷⁷。30年來不斷延長，自1992年引進移工至1977年間，僅允許一聘1年，得延長1年¹⁷⁸，不得再次申請。1997年更改為一聘2年，可延長1年，亦即總共3年¹⁷⁹。2001年將移工得於境內工作期間延長為累計6年，一聘3年，期滿得再申請入國工作一次，但3年屆期必須出境40日¹⁸⁰。此後維持一聘3年迄今，但總年限在2007年延長至9年，3年屆期至少須出國1日、2012年延長至12年¹⁸¹，2015年再將家庭看護工之累計得在境內工作期間延長為14年¹⁸²，止步於支領勞保年金的門檻（15年）之前——儘管移工請領勞保年金可能是超前時代的顧慮¹⁸³，因為家庭看護工未強制納保勞工保險，實際上只有約五分之一的雇主為其投保¹⁸⁴。2016年雖刪除3年屆期至少須出國一日的規定，但移工的聘僱許可一聘最長仍為3年，而

177 作為比較，倫理與經濟學界討論暫時性移工在境內工作期間應以多久為宜，重要的政治哲學家Miller認為應短至1年，而Carens認為長至5年以上的居留即應使移工取得永久居留之資格。另一方面，經濟學家Ruhs對暫時性移工制度抱持支持態度，希望鼓勵更多的國家接納跨國移工，為此他們非常強調移工制度的成功關鍵在於恪守暫時性，俾確保移工在期間到後返國，而他們的建議的移工居留期間為2年。JOSEPH CARENS, *THE ETHICS OF IMMIGRATION* 113-14 (2013); DAVID MILLER, *STRANGERS IN OUR MIDST* 99 (2016); MARTIN RUHS, *THE PRICE OF RIGHTS: REGULATING INTERNATIONAL LABOR MIGRATION* 177 (2013).

178 1992年5月8日訂定公布之就業服務法第49條。

179 1997年5月9日修正公布之就業服務法第49條。

180 2001年12月21日修正公布之就業服務法第52條。

181 2007年6月14日修正公布之就業服務法第52條。

182 2012年1月19日修正公布之就業服務法第52條。

183 因為立法院協商是閉門會議，沒有公開資料可以確切知悉協商過程，這裡有關勞動保險年金的論點是由委員會記錄所得之推論。參立法院公報，104卷36期，頁342，趙天麟委員發言（2015年），其提及移工可否請領勞工保險年金：「如果我們讓他們（按：移工）可以請領老年年金到15年以後，政府要增加的費用可能就不在是少數，恐怕會有上千億元，或好幾千億元的支出，因此一次金的給付，或許可以減少政府財政上的負擔，然而，此舉卻同時會產生有違國民待遇原則的狀況。這個問題該怎麼解呢？畢竟這會涉及到很價值性的考量。」

184 勞動部，105年外籍勞工管理及運用調查（2016年），頁38，<http://statdb.mol.gov.tw/html/svy05/0542analyze.pdf>（最後瀏覽日：2021年1月25日）。

僱傭契約亦規定為定期契約，以3年為限¹⁸⁵。

延長移工在境內工作期間之修法，一直都是由雇主端所發起，主要的理由是頻繁勞力轉換對雇主而言並不經濟，雇主投入訓練成本後，不欲移工太快離開，穩定而熟習工作環境與技巧的勞力供給，對雇主有利，強制移工離境更是造成人力空窗的不便¹⁸⁶。主管機關曾反對聘僱許可與居留年限延長，指出其中所隱含的人權問題，包含可能必須允許家庭重聚和全面性的平等待遇、以及廢除定期契約等，而雇主對隨之高漲的成本必然無法接受¹⁸⁷。如此發言顯示維持「暫時」居留的功能之一，即是正當化重要權利的剝奪、差別待遇與廉價化移工勞力。

定期契約本身就是一種不利的勞動條件，勞動基準法下僅得例外使用，而藍領移工制度卻將例外變為原則。勞動基準法第9條對以定期契約聘僱本國勞工之情形嚴格限縮，限於臨時性、短期性、季節性的工作始得締結定期契約¹⁸⁸，繼續性工作不得以定期契約聘僱。且實務上係以工作性質來判斷僱傭契約得否為定期契約，不受

¹⁸⁵ 現行就業服務法第52條。

¹⁸⁶ 如1997年就業服務法第49條之修正理由：「……外國人，於其入境後，約需三個月至六個月始能熟悉工作，再工作一年餘即需遣返，造成雇主之不便。」2007年同法第52條（條號移列）之修正理由：「……外國人在中華民國境內工作期間累計不得超過計九年，則該外國人可能在技術、工作能力及效率最佳狀態之際，即被強制不能繼續留在台灣工作，雇主必須重新招聘員工加以訓練，實務上增加雇主人力訓練成本、降低工作效率。」；2002年同法第52條修正理由：「……由於就業服務法明訂外勞在臺工作最長年限九年，形成部分優秀外勞期滿不能繼續在臺工作，反成韓、星等國等著挖角的對象。再者，外勞因曾在臺工作，不僅與雇主比較容易配合，技術也頗專精，不僅臺商愛找臺灣工作期滿的外勞，韓國、新加坡也樂於承接，讓臺灣訓練出的勞動力成為外國挖角對象。」分別可於立法院法律系統查閱，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?008F463B2D2200000000000000000000320000000070000000^03615107110900^0009B001001>（最後瀏覽日：2021年2月22日）。

¹⁸⁷ 立法院公報，96卷50期，頁202-203，曹愛蘭勞工委員會副主任委員發言（2007年）。

¹⁸⁸ 勞動基準法第9條。

契約形式拘束¹⁸⁹。但在移工的情況卻反其道而行，就業服務法要求藍領移工必須以定期契約聘僱，儘管其所從事者為繼續性工作，續約亦同¹⁹⁰。定期契約低估移工的經濟貢獻，影響攸關年資長短之權益如資遣費、勞工保險之給付、休假等；前後二定期契約銜接上也可能有空窗期間，而移工自然通常於僱傭契約期滿時返國省親或進行重要的人生活動（如結婚），此時既非僱傭契約存續期間，雇主也不必提供有薪特別休假、婚假或喪假等。

定期契約也使勞雇間的權力關係進一步向雇主傾斜，因為每次屆期都是雇主可自由評估是否續聘移工的時點。最明顯的例子是，2016年原就業服務法第52條移工3年強制出國一日的規定取消後，本係期望取消過去聘僱許可3年屆期必須由仲介重辦入國手續對移工所造成的不必要經濟負擔。但移工團體批評仲介因應修法，改於僱傭契約屆期後收取檯面下之「買工費」，才為移工辦理聘僱許可的展延或提供工作機會¹⁹¹。這個現象是否為業界慣行或許尚待後續研究確認，但此一批評顯示，定期契約屆期的不穩定性創造了仲介介入與掌控移工工作權利的風險，架空移工法定權利。

強制定期契約的設計儘管對於移工的勞動條件有負面效應，而且與從事相同工作的本國勞工相比，係對其勞動條件加諸基於國籍之差別待遇。但由於移工之定期契約原本係其短期居留身分的配

189 如行政院勞工委員會89年3月31日（89）台勞資二字第0011362號函；最高法院103年度台上字第2066號民事判決：「工作是否具有繼續性，應以勞工實際從事工作之內容及性質，對於雇主事業單位是否具有持續性之需要而定，亦即與雇主過去持續不間斷進行之業務有關，且此種人力需求非屬突發或暫時者，該工作即具有繼續性。又勞工實際從事之工作內容，如與其所簽訂定期勞動契約之約定不符，即難認雇主係因該定期勞動契約所定特定性工作之需求而簽訂該契約，應認不符勞基法第九條第一項所定因特定性工作得簽訂定期契約之情形。」

190 就業服務法第46條第3項。

191 如郭志榮，仲介狂收買工費 台灣形同蓄奴國？，公視新聞議題中心，2019年10月3日，<https://pnn.pts.org.tw/type/detail/2473>（最後瀏覽日：2019年12月2日）。

套，而允許外國人居留期間長或短，則屬於主權國家決定外國人入境條件之權力，因此儘管移工居留期間越短，其勞動法律關係越不安定、勞動力越形賤價化，可是由於居留長短屬於移民事項之管制，便掩蓋其劣化勞動條件的效果，並使外國人勞動條件的平等保護，在面對居留期間的設定時，似無適用餘地。實則，涉及外國人身分的居留期限、與涉及勞工身分的僱傭契約定期與否，在技術上係可分離，並無規定僱傭一律採定期契約之必要。而廢除定期僱傭契約之限制，有助於避免國境管控的居留條件，對於勞動契約造成負面的效應，亦得以在不影響國家邊境管制權力之餘，調整勞雇權力關係，使之更為衡平。

二、健康檢查：國境對移工之健康監理

人的跨國移動與接觸，確實有擴散特定疫情的可能，因此適當的國境健康管理是必要的，但是藍領移工所面對的健康檢查制度，稍有不慎即易雜糅種族與階級偏見，具象地將藍領移工視為入侵政治體（body politic）的外來異物。

首先，移工入境前及入境後、都需自費進行頻繁地健康檢查，現行規定雖已「簡化」為入境前、入境後3工作日內及6個月、18個月、30個月各一次¹⁹²，但入境後18與30個月之檢查，實在已很難從國境防疫之角度予以正當化，而已是針對特定國籍外國人，加諸具有高度侵入性的差別待遇。

再者，健康檢查項目的選擇不一定是傳染途徑與流行疫區等防疫考量，而受其他政治社會因素影響。過去有些將移工視為治安威脅所生的檢驗項目，例如1992年至2004年間藍領移工健康檢查項目包含安非他命、嗎啡與大麻反應，後因檢驗機構不堪負荷而取

¹⁹² 受聘僱外國人健康檢查管理辦法第5條。所謂簡化是相對於2004年之前的規定要求每六個月檢查一次。

消¹⁹³，1997年身體檢查項目包含「精神狀態」，作為排除「不安全」移工的方式¹⁹⁴。又懷孕不是疾病而是能力，但女性懷孕的能力卻也讓他們成為疑似「變相移民」者跟不合格的勞動力，在2007年之前，女性藍領移工強制於入境前後驗孕¹⁹⁵，2007取消入境後的驗孕規定，但入境前仍須通過驗孕才能申請簽證，直到2015年才取消入境前的驗孕規定¹⁹⁶。

即使是傳染病項目，是否成為檢驗項目也不全然能以傳染可能來說明，例如B型肝炎、梅毒及HIV/AIDS之傳染途徑類似，即透過體液、血液之接觸傳染，但3種疾病的處理完全不同：B型肝炎項目在2009年取消檢查，理由是移工不太可能造成他人B型肝炎感染，但相同傳染途徑的梅毒迄今仍然屬於檢驗項目內，2007年以後梅毒檢驗不合格若在境外則不得申請簽證，在境內者得經治療後複檢。至於HIV/AIDS，2015年之前，我國對外國籍之感染者係一律拒絕入境或令其出境¹⁹⁷，這雖是對所有外國人一律適用的規定，但對藍領移工有不成比例的不利影響，因為只有移工須接受定期強制身體檢查。2015年後，HIV/AIDS感染之入境居留限制取消，因此

193 張育菁、黃志傑、林詠青、吳麗琴、何麗莉、吳怡君，1989-2015年臺灣受聘僱外國人健康檢查制度的演進與革新，疫情報導，33卷1期，頁14（2017年）。

194 顧玉玲，移工運動的主體形塑——以「家事服務法」推動過程為例，「台社二十週年會議：超克當前知識困境」學術研討會，台灣社會研究季刊社、世新大學台灣社會研究國際中心主辦，頁5（2008年9月27日）。

195 在就業服務法最初立法之時，提案中原有對女性外籍移工驗孕的規定，遭立法院於二讀及三讀審查時，以涉及懷孕與職業歧視之理由刪除，但主管機關卻再度將驗孕規定訂於就業服務法的子法中，然而此一明顯違法的行政命令卻從未有機會透過法院審查而被挑戰。立法院公報，81卷31期，頁65-68，朱高正、林正杰、李友吉委員發言（1992年）；立法院公報，81卷32期，頁27-29，李慶雄、朱高正委員發言（1992年）；1992年7月27日訂定發布之外國人聘僱許可及管理辦法第15條。

196 2004年1月13日修正公布之受聘僱外國人健康檢查管理辦法第5條第1項第5款；2007年10月2日修正公布之同法第7條第1項。

197 2007年6月14日公布修正之人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第18條。

亦不再是移工強制健檢項目，但「外籍勞工健康項目檢查表」卻附錄「愛滋篩檢與治療費用通知書」，以4種語言告知移工，非本國籍者在臺灣愛滋治療必須自費，費用高昂，建議欲來臺工作者自行篩檢，亦建議感染者在母國治療¹⁹⁸。這些不同的處理顯示健康檢查項目並不是單純科學評估的決定，而包含對疾病的評價，投射在國境控管上。

現行藍領移工進行的健康檢查項目包括結核病X光、漢生病、梅毒血清、麻疹抗體、腸內寄生蟲糞便及身體檢查（指身高、體重、血壓、脈搏等）¹⁹⁹，已淡化上述過去健檢承載過多外在負面投射的情況，逐漸回歸理性防疫考量。但這其中仍然隱藏階級與職業之污名與歧視，「藍領從嚴、白領從寬」是官方為了避免衝擊所謂「先進國家」外國人而提出的政策²⁰⁰。與藍領移工相較，白領移工僅有外語教師一種工作，在申請或展延聘僱許可時必須健康檢查，項目不含漢生病與寄生蟲，其他工作聘僱許可之申請不需要健康檢查，更不是入境條件。因此來自同樣國家同樣區域的外國人，會因為申請工作項目不同，而有不同的健檢要求，此種基於職業不同所生之差異，預設不同職業者有不同的感染與傳染他人之風險，有何確切事實基礎，不免可疑。這些例子都顯示國家選擇只將對身體直接而頻繁的干涉措施，加諸於來自經濟後進國家、從事3K工作的外國人身上。

藍領移工健康檢查在境外不合格者不得申請簽證²⁰¹。入境後若不合格，過去即便只是寄生蟲檢查未通過，都會導致令其出國之處

198 衛生福利部疾病管制署，外籍勞工健康檢查項目表，<https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/7/2017/05/%E5%A4%96%E7%B1%8D%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E9%A0%85%E7%9B%AE%E8%A1%A8.pdf>（最後瀏覽日：2018年2月1日）。

199 受聘僱外國人健康檢查管理辦法第6條。

200 許須美，外勞與國內防疫問題，疫情報導，12卷11期，頁340（1996年）。

201 受聘僱外國人健康檢查管理辦法第5條第2項。

分（即遣返）²⁰²。「立即遣返」是移工只能是健康勞動力、生病的移工是外來污染的思考。特別是對於在居留後期罹病的移工而言，他們更有可能是在工作期間中遭受感染，乃至是一種職業災害，但一律以遣返處理，無異於以國界管制的邏輯，剝奪被傳染者身為勞工應享有的健康與勞動權利。本國勞工在勞動基準法下應有1年30日之半薪病假，2年內未住院傷病假與住院傷病假合計1年²⁰³。對於罹患傳染病之本國勞工，主管機關認為「會傳染」並不構成解雇事由，雇主應以留職停薪或其他可避免疾病傳染之方式處理，仍不能醫癒始得以「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」為由，依法資遣²⁰⁴。相較之下，以「健檢不合格」認其違反居留條件而遣返移工，雇主便被免去承擔受雇人健康風險的責任，毋庸依法資遣，移工更因離境而失去全民健康保險下應享有之保險給付（醫療），在移工須負擔部分保費的前提下，遣返剝奪的不只工作權，亦有健康權與社會安全之權利。

此外，遣返機制會影響醫療診斷及治療的流程。醫療檢驗的判讀有其模糊地帶，初步篩檢不合格並不代表確診，但篩檢結果出爐後，受限於遣返時程與經濟限制，移工通常無餘裕去進行更精密的檢測以確認診斷是否正確²⁰⁵。此外，有研究基於2009至2012年間資料指出，雇主常在移工健康檢查獲得疑似罹患肺結核之初步結果後，不待痰液培養及抹片結果，亦不按照規定進行抗結核藥物投藥，即解聘移工令其返國，在194位遭解聘返國之移工中，僅有不到3成按規定服藥14日降低傳染力後搭機，無異令其他乘客暴露於感染風險中²⁰⁶。不依規定投藥立即遣返，在實務上係因擔憂移工若

202 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第46條第2項第3款。

203 勞工請假規則第4條。

204 內政部1985年6月15日台內勞字第321153號函。

205 黃郁惠，移工沉默的身體：分析台灣遣返結核病移工之醫療政策的權力意涵，南華大學應用社會學系碩士論文，頁40（2013年）。

206 林欣宜等，外籍勞工結核病診斷及遣返作業之回顧——以中部地區為例，疫

獲知即將遭遣返，會在遣返前的服藥期間「逃跑」，從而境管必須控制移工行方的考慮，反而阻礙了公共健康政策目標的達成²⁰⁷。

目前對於健康檢查不合格的處理與遣返已有所改善：梅毒與寄生蟲不合格者原則上允許移工於一定期間治療後複檢，並對肺結核與漢生病不合格者提供都治服務（Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS）²⁰⁸。這些修正使得我國移工的健康檢查制度往ILO第97號公約第5條所發展出的，不得以無礙於工作之疾病為由而遣返移工之要求靠攏，是正面的發展²⁰⁹。不過複檢不通過、未完成15日之都治服務或罹患多重抗藥性結核病仍屬不合格而會遭遣返。更重要的是，雇主是否願意配合移工的診治仍是一大挑戰，由於暫時性移工並不享有居留保障，其必須能一直在僱傭關係內始得繼續居留，因此移工能否獲得良好醫療，事實上取決於雇主有意願維持僱傭關係，形同雇主對移工能否接受診治之「同意權」²¹⁰。在結核病的案例中有高比例的雇主選擇不繼續聘用，在此狀況下移工之聘僱許可會迅速被主管機關廢止，連帶失去居留許可及健保醫療²¹¹。最後，定期的檢驗亦會使雇主得以不斷更新移工特定項目所取得的健康資訊——而這些資訊是移工被要求自費檢驗所得。在國境管理的目的之前，移工的健康隱私的適當保護顯得毫不重要，移

情報導，29卷8期，頁94、98（2013年）。

207 黃郁惠（註205），頁63。

208 衛生福利部衛生管制署，都治計畫https://www.cdc.gov.tw/Category/ListContent/tFo1rKqcN4MFvA5P1tuM-w?uaid=2_MqVkYDApuybKt2e_uSeg（最後瀏覽日：2019年10月25日）。

209 參註97及其相應之本文。

210 黃郁惠、齊偉先，罹患肺結核的移工在台灣醫療照顧制度中的治療經驗與賦權，台灣公共衛生雜誌，37卷1期，頁68、70（2018年）。

雇主不願意繼續聘僱移工而導致移工必須離境，在具體狀況中不一定抵觸ILO第97號公約第5條的要求，因為疾病也有可能實際上有礙工作；而真正能夠比較確保居住安全的第8條（要求不得因移工罹病中斷僱傭關係而使其離境之規定），對於暫時性移工卻不適用。參前述貳、二、（二）之說明。

211 2016年的數據顯示移工來台治療的比例是23.1%。黃郁惠、齊偉先（註210），頁68。

工於是更加暴露於傳染病污名的影響。

另一方面，當國境管制對移工施加確實而頻繁的檢驗，以免其危及共同體之健康時，國家對於雇主就移工健康所應負起的職業安全責任卻怠於督促其履行。在職業安全衛生法體系下設有監測職業安全的勞工健康檢查制度，分為一般健康檢查與從特別危害健康作業者之特定項目健康檢查²¹²，此類檢查是雇主應對勞工提供的職業健康服務，雇主應就特殊檢查結果，參照醫師建議，調整勞工工作內容，並彙整成健康檢查手冊供勞工參考²¹³。對於移工而言，職業安全衛生法下的健康檢查特別重要，因為移工從事的工作包含特殊製程與特殊時程工作，通常是職業衛生安全法上之特別危害健康之作業，保護不足的狀態會對移工造成高度風險。但實際執行上勞工健檢普及率低，雇主責任並未落實²¹⁴。

再者，職業安全衛生法針對勞工就職時，亦訂有新進勞工之體格檢查，這是工作適性之判斷，以避免危害勞工安全健康。例如高溫作業不適合高血壓者、噪音作業不適合心血管疾病者，項目主要包括視力、聽力、血壓、尿蛋白、膽固醇等²¹⁵。但在實務上，移工入境的健康檢查，卻被解為可以取代職業衛生安全法下對新進員工一般體格檢查與特殊體格檢查²¹⁶，儘管二者在項目與目的上相差甚遠，但制度上卻容許以國家以自我保護的措施（移工體檢）取代保護勞工的措施（新進勞工體格檢查），移工身為外來傳染源的面向，遠遠重於身為勞工應受職業安全的受保護者的面向。

最後，勞工就職的體格檢查不包括B型肝炎、梅毒與

212 職業安全衛生法第20條第1項。

213 勞工健康保護規則第21條。

214 鍾佩華、尤素芬、鄭雅文，我國勞工健康檢查制度之現況與問題，台灣公共衛生雜誌，28卷2期，頁163-164（2009年）。

215 勞工健康保護規則附表11。

216 勞工健康保護規則第14條。

HIV/AIDS或其他傳染性疾病，而基於對傳染病帶原者的保護，對於不在法定體格檢查項目之疾病，雇主應不得要求檢驗，並不得因病而給予就業與工作上之不公平待遇²¹⁷。相較之下，移工健康檢查因病不通過的法律效果是無法申請簽證，在這個意義上，國境間接發揮代替雇主以病為由挑選求職人的效果，這些扣連入境與居留資格的身體條件，在入境前就發揮作用。

綜言之，頻繁的藍領移工健康檢查，使移工整段居留期間都暴露在雇主是否同意繼續聘僱，使其能居留並接受治療的風險中，從而再度凸顯在受制於異國性、欠缺居留權利的狀況下，其外國人身分架空其本於勞工身分而應享有之權利。又國家對移工健康檢查之積極執行與對雇主之勞工職業安全義務怠於貫徹，形成強烈對比。從落實移工勞動條件平等、盡可能不使對外國人之管制影響勞動權利的角度觀之，有必要檢討入境後，在超過檢疫及疾病潛伏期間後之健康檢查是否仍有必要，又縱有必要，移工在居留期間罹患疾病，於居留許可屆期之前，應容許其享有相對安定、不受制於雇主意願的居留權利，並貫徹勞動基準法上對於患病勞工之保障。

三、禁止轉職：不自由的勞動力²¹⁸

移工的異國性最明顯的展現，是透過國境管制機制剝奪移工的就業與轉職自由。如前述，移工能獲得入境、聘僱及居留許可，是綁定在受聘於特定雇主、從事特定職務、並在特定期間內，於特定地點提供勞務的條件之上。因此未經主管機關同意的職業轉換，即違反入境及居留的條件。

²¹⁷ 傳染病防治法第12條。

²¹⁸ 不自由勞動力（unfree labour）相對於自由勞動力，指的是無法自由在勞動市場上以契約交易的勞動力，是一種以政治法律機制分配、利用與留駐勞力的生產關係。See generally ROBERT MILES, CAPITALISM AND UNFREE LABOUR: ANOMALY OR NECESSITY? 175-81 (1987).

2001年起就業服務法開始允許移工在特殊情況下轉換雇主²¹⁹，主要是僱傭契約出於不可歸責於移工之事由提前終止²²⁰，但原則上必須從事同一工作類別，不得跨業轉職²²¹。所謂不可歸責於移工之契約終止，有些屬於情事變更，例如被照顧者死亡、船舶沉沒無法繼續作業、雇主關廠歇業；有些肇因於雇主違法，例如違法扣留護照導致聘僱許可被撤銷、或移工遭到性騷擾；也有可能出於雙方之合意。有轉換程序不代表移工享有轉職的自由，因為移工並無單方面決定轉職的可能性，始終需要雇主意願上的配合。

轉換程序對於勞雇各有制度性的不友善。對移工而言，轉換期間承受相當的經濟與時間壓力。移工進入轉換程序時，因尚無新聘僱許可，自然無法工作——否則構成許可外工作，將成無證移工。同時我國不許移工參加就業保險²²²，而無失業給付可支領。法制上少數可能的經濟支持是資遣費（如關廠歇業業務緊縮等），但這只適用於受勞動基準法保護的移工²²³，且事實上索求之困難自不待言。再者，移工轉換程序有時間限制，移工若未能順利於轉換期間內（原則上60日，經許可得展延60日）媒合到願意承接的雇主²²⁴，移工便須返國。值得注意的是，當雇主違反保護移工之法律而被撤銷聘僱許可，此時移工亦會進入轉換程序，移工乃弔詭地受到保護性法律的「懲罰」，因為其必須承擔轉換期間的經濟損失與結果的

219 不過轉換程序實際上到2003年子法「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」公布後才算真正實施。

220 就業服務法第59條。

221 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第8條。

222 就業保險法第5條第1項。

223 勞動基準法第11條。

224 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第11條第1項。例外在移工受人身侵害而雇主僱傭許可被廢止的情形，移工轉換作業沒有僅得延長一次的限制。

不確定性。在雇主方面，制度上固允許勞雇合意讓移工轉出²²⁵，但由於辦理轉換之期間內，原雇主不能遞補移工，這降低了雇主讓移工進入轉換程序的意願，因此有人力壓力的雇主更傾向直接解約讓移工回國，逕行引進新移工²²⁶，或者直接拒絕移工轉換雇主。

暫時性移工遭受不同程度的職業自由剝奪，在各國的客工制度都很常見²²⁷，移工作為不自由的勞動力，會升高其受到剝削的風險，若涉及移工背負高額債務等情況，更可能成為強迫勞動²²⁸，成為前述ILO所稱的歧視性就業系統²²⁹。正如經社文公約第23號意見書所言：移工「易遭剝削、被迫長時間工作，接受不公平工資以及危險和有害健康的工作環境。惡劣的勞動做法又加劇了這種弱勢，例如給予雇主控制移徙工人的居留身分，或將移徙工人綁定一個特定的雇主」²³⁰。然而，前亦述及，職業自由的剝奪固然是國境權力間接影響外國人勞動條件最重要的面向，但在一定年限內係與保護移工之諸公約相容²³¹，而不生違反就業平等之疑慮。

此種對職業自由的剝奪²³²，不可能加諸於本國國民，在這個意義上，只有公民才有可以是勞動市場上的自由勞動力，而移工若要

225 屬於就業服務法第59條第1項第4款「其他不可歸責於受聘僱外國人之事由者」，即可合意轉出。

226 顧玉玲，跛腳的偽自由市場：檢析台灣外勞政策的三大矛盾，台灣人權學刊，2卷2期，頁97-98（2013年）。

227 ILO, *supra* note 114, ¶ 357, 359.

228 SSENYONJO, *supra* note 23, at 431.

229 參註107及其相應之本文。

230 UNCHR, *supra* note 27, ¶ 47(e).

231 ILO第143號公約第14條與移工公約第52條之明文容許。詳前貳、二、(三)之說明。

232 只能從事特定職業與禁止轉職（換雇主），本文認為均是對於職業自由的剝奪，但是不同意見參邵允鍾認為禁止轉職並未剝奪移工之職業自由，因為移工已經選擇來臺從事此一行業，只是不可以在另一個雇主的雇傭下從事同一行業，所以並未干涉其選擇從事哪一個行業的自由。邵允鍾，從憲法角度檢視移工不得自由轉換雇主之相關規定：以平等權論述為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁75（2007年）。

求有轉職自由，其實已是在要求擁有公民才可具備的特性²³³。也因此，暫時性移工享有平等職業自由的訴求，根本地挑戰以主權國家為核心的政治架構與想像²³⁴。

不過，即便尊重就業國僅將特定工作機會開放給移工的政策考量，仍然有許多措施可以降低轉職禁止的強度，與其對工作條件的負面影響，達到外國人地位與勞工地位的適度分離。例如按移工公約所設年限，容許移工在一定期間後，至少得於特定產業內自由流動、容許移工納入失業保險、或以其他方式提供移工失業時的經濟安全網，採取有效措施避免移工負擔過度債務（例如不仰賴私人仲介的國對國引進制度），以降低轉職禁止所可能造成的強迫勞動狀態。

四、居住與行方控制：私人化的國境管制權力

為了確保移工不會進入自由的勞動市場，並防制無證移工，移工制度須細密掌握移工從入境到出境之行蹤。這些措施化身為邊境管制的延長，並將責任轉嫁於雇主之手而成為私人化的國境管制權力，雇主對移工的指揮監督權（也就是僱傭關係的從屬性）也因之延伸至工作領域外。

我國法律上並不要求移工居住在雇主所指定的處所，但除了經濟考量，移工本國所提供定型化契約通常要求移工必須居住在雇主指定處所²³⁵，產業移工的雇主並得由薪資中扣除新臺幣5,000元以

233 NANDITA SHARMA, HOME ECONOMICS: NATIONALISM AND THE MAKING OF “MIGRANT WORKERS” IN CANADA 98 (2006).

234 Fudge, *supra* note 115, at 131.

235 例如菲律賓移工所適用之僱傭契約LBR 03-C-IW第5條規定：「甲方於工廠所在地或附近提供免費團體住宿，乙方應居住於宿舍內並不得外宿。」馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心，<http://www.meco-labor.org.tw/Forms/LBR%2003-C-IW.docx>（最後瀏覽日：2017年2月3日）。當中免費住宿的規定引發臺灣雇主與菲律賓移工之間有關是否得扣除費用之爭議。

下的食宿費用²³⁶。移工宿舍管理甚至成為一種標榜軍事化秩序的產業，以工作日起床與就寢時間限制、門禁管理、早晚點名、訪客限制、夜間巡床、週日全體打掃、違反住宿規定構成重大違規等等，招徠雇主青睞²³⁷。

事實上，我國法制上也確實課予雇主管理移工生活起居的職責：「外國人生活照顧服務計畫書」²³⁸要求雇主訂定住宿規則、生活須知、對外國人介紹法令與風俗節慶等管理與照顧項目。此外，「聘僱之外國人妨害社區安寧秩序，經依社會秩序維護法裁處」，會構成雇主被中止引進移工的事由²³⁹，這意謂在下班時間後，雇主仍被認為有確保移工不妨礙社區安寧的義務。而移工尚且需為其所受的全時性監管付（住宿）費。

家庭看護則因居住在雇主家中，工作與休息的界線模糊，義務不定時不定量且隱私匱乏。家庭看護工之食宿費用，未如產業移工一般依法從薪資中扣除，主管機關卻認為食宿構成其實質所得的一部分²⁴⁰，並以此為其遠低於基本工資之收入辯護。但這樣的說法猶如先要求員工改服24小時在勤之勞務後，再聲稱此種出勤方式等同於雇主以實物給付房租，並以此為由扣減現金薪資——以更長的工

236 行政院勞工委員會2007年7月13日勞職外字第 0960506354 號函。

237 網路上有許多外勞宿舍管理廣告以及嚴格的宿舍生活公約可供參考，如凱翔人力資源管理公司，外籍勞工生活管理實務，<https://volant-manpower.weebly.com/23487332933164929702.html>（最後瀏覽日：2019年10月13日）。

238 計畫書規定了雇主依法必須提供的基本設備跟生活條件，飲食、個人生活空間、防火設備、盥洗、祈禱、生活輔導與翻譯等。地方政府負責監督生活照顧計畫的實施，輔導雇主按照計畫確實辦理。雇主違反計畫時，地方主管機關應通知雇主改善，拒不改善可能影響未來移工名額的申請或甚至聘僱許可遭撤銷，在後者的情況自然會影響到其所聘僱的移工就業的權利，這是我們一再在移工制度中看到的，移工間接承受保護法令的不利後果。

239 雇主違反就業服務法第54條規定不與許可及中止引進裁量基準第7款。

240 勞動部，家事外勞合理調薪適用未來新申請案，8月底前協商調薪方式，2016年11月3日，<https://www.mol.gov.tw/announcement/27179/23544/>（最後瀏覽日：2017年6月5日）。

時換來更少的現金薪資。

避免移工失聯是臺灣移工制度的重大考量，雇主有義務即時²⁴¹向警察機關或境管機關通報「逃跑外勞」，亦即連續曠職3日失去聯繫的移工²⁴²。對於失聯3日內之移工，雇主「得」立即通報警察機關及移民機關「協尋」²⁴³。一經連續曠職3日之通報，移工的聘僱許可可即遭廢止²⁴⁴，並設有獎金鼓勵人人通報疑似失聯移工²⁴⁵。移工行方不明，雇主不會受到行政懲處²⁴⁶，但可能會遭受相當的不便，例如產業移工之雇主不能立即聘僱新移工，必須6個月後始能申請遞補；社福移工行方不明，雇主則須等待3個月²⁴⁷。

過去雇主一再敦促取消移工行方不明時，等待申請遞補人力之期間，但主管機關認為這段期間是促使雇主盡力防免移工不告而別的必要設計。由於實務上移工轉換雇主所需的時間大約是3個月，因此若移工行方不明時雇主可以立即接續聘僱移工，雇主便有道德風險容任移工行方不明，而不願改善勞動條件與勞雇互動以留住移工²⁴⁸。很諷刺地，按主管機關的看法，移工能促使雇主改善勞動條件的槓桿，是其主動「逃跑」的可能——換言之，是移工可能自願進入無法律保障的地位的能動性，制衡了雇主放任條件惡化的傾

²⁴¹ 就業服務法第68條。

²⁴² 就業服務法第56條。

²⁴³ 就業服務法第56條第1項但書。

²⁴⁴ 就業服務法第73條。

²⁴⁵ 民眾檢舉違反就業服務法相關規定獎勵金支給要點第7點。

²⁴⁶ 2007年前移工行方不明時，雇主仍必須繳付就業安定費。參2007年5月4日修正前之就業服務法第55條。

「就業安定費」是雇主引進移工後，原則上須按人數繳交的固定行政費用（參就業服務法第55條第1項），意在墊高雇主聘僱移工的成本、降低聘僱移工的誘因，也寓有「使用者付費」之意，即雇主為引進移工所造成的社會成本付費。就業安定費之立法目的參立法院公報，81卷19期，頁45，關係文書（1992年）。

²⁴⁷ 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第17條之1。

²⁴⁸ 立法院公報，102卷66期，頁414，勞工委員會職訓局廖為仁副局長發言（2013年）。

向，但這無異承認移工作為不自由勞動力（不能轉換工作）的法律設定，對其勞動條件帶來根本的傷害。

所謂移工「逃跑」，乃是移工不得自由轉換工作制度下的必然產物。這個詞彙將移工貶為竄逃中的犯罪者，但也一語道盡移工作為不自由勞力的本質——若想走，只能逃。比起改善勞動條件，現實上扣留護照及強制儲蓄更可能是被採用來避免逃跑的手段，早期甚至是官方提倡的方法²⁴⁹。現行就業服務法禁止雇主扣留移工證件及薪資²⁵⁰，但扣留護照的禁令實務上不難規避，因為主管機關認為雇主只要讓移工填妥保管意願書即不屬非法扣留²⁵¹。強制儲蓄部分，儘管一開始即違反勞動基準法薪資應全數發給的規定²⁵²，過去行政命令仍明文允許雇主可以扣留30%的薪資²⁵³。2008年後因有人口販運嫌疑而禁止強制儲蓄，雇主並應檢附雙語薪資明細表，不過根據勞動部調查，即使在2016年仍約有5%的移工其薪資雖係透過轉帳，卻不持有存摺²⁵⁴。

總之，移工屈從在雇主全時全地、制度性的生活控管權力之下。一般而言，勞雇關係的重要特徵之一是從屬性（subordination），勞工接受雇主針對不特定事項的指揮監督，雇主之於勞工則

249 顧玉玲，自由的條件：從越僑殺人案看台灣家務移工的處境，國立交通大學社會與文化研究所碩士論文，頁140-141（2010年）。

250 就業服務法第57條第8款。

251 行政院勞工委員會93年08月12日勞職外字第0930204260號函。

252 勞動基準法第22條第2項。

253 外國人聘僱許可及管理辦法（已廢止）第30條規定：「雇主得與外國人訂立契約，以外國人名義在金融機構開立帳戶，將工資百分之三十以下數額存儲生息，俟其離境時領回。」這個作法引發美國國務院人口販運報告的關注，最終取消也跟此一壓力有關。OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS, *Trafficking in Persons Report 2009*, at 275 (2009), <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/123357.pdf> (last visited Jan. 23, 2018).

254 勞動部（註184），頁13、35。2016年勞動部的官方統計顯示48%的產業移工與23%的社福移工薪資發放透過銀行轉帳，但其中12%的產業移工與29%的社福移工，不持有存摺。

享有管理上的特權（management prerogative）²⁵⁵。這是為了經濟效率的目的所難以除去的科層與管理²⁵⁶，無論針對本國或外國勞工都存在。然而，移工的特殊處境，是雇主的管控已經超越了經濟生產關係中效率與管理的層面，而承擔了國家移民體制裡，須始終明確掌握移工行蹤的任務，形成私人化的國境管理權力、過度向雇主傾斜的勞雇關係並惡化勞動條件。有論者認為雇主溢流到工作場所外的對於勞工之控制權能，已構成宰制關係（domination）²⁵⁷，但從傳統平等保護操作的角度來看，對移工全時性的生活或行蹤監理，既沒有法令強制住宿、又可能沒有處境相當的本國勞工可供比較，是以難以辨識出差別待遇。

實則，移工食宿既係其所購買之服務，便應回到食宿服務的本質，而不能是國境與勞動管理的延伸。雇主對於移工住宿的管理，不應超出出租人對於其物業之管理權限，同時負有維修義務，故雇主若怠於維修、及所提供之餐點與居住條件低於安全與衛生應有之標準，亦應對移工負擔債務不履行之責任，即返還移工所支付之費用。相對地，雇主對移工下班後的個人行為沒有責任，所謂移工在下班後之不當行為會導致雇主被中止引進移工云云，應徹底取消，因為這不僅反映移工是治安隱憂的偏見與污名，要求雇主負擔超過工作以外的生活管理秩序也是對移工的幼稚化。

255 E.g., DAVIDOV, *supra* note 16, at 36–37; HUGH COLLINS ET AL., *LABOUR LAW* 132–33 (2012); HUGH COLLINS, *EMPLOYMENT LAW* 10 (2d ed. 2010); OTTO KAHN-FREUND, *KAHN-FREUND'S LABOUR AND THE LAW* 14 (Paul Davies & Mark Freedland eds., 3d ed. 1983).

256 DAVIDOV, *supra* note 16, at 54.

257 Virginia Mantouvalou, *Human Rights and Unfair Dismissal: Private Acts in Public Spaces*, 71 MOD. L. REV. 912, 914, 925 (2008).

伍、結論

本文探究何以儘管人權法確立了適用於外國人的勞動權利平等保護原則，但在跨國暫時移工制度中，許多對於移工權利影響重大的設計，卻不易在平等勞動權利的規範下被挑戰。本文主張，由於國境管控措施構成了暫時性移工制度的骨幹，而國境管控是傳統上勞動權利平等保護無從介入，或採取包容立場的領域，因此當移工制度的入境居留條件同時負面地影響暫時性移工的勞動條件時，其對人權法勞動權利平等保護的實踐，便造成了內在的緊張關係。

暫時性移工制度凸顯出以國家為中心的國境管控（以及連帶的工作機會分配）規範，之於普世、一般的勞動人權規範，二者間的張力。在二者的權衡中，人權法之實踐經驗所提示的是，盡可能讓移工之勞工身分獨立於其外國人身分的規範領域，有助於避免勞雇極端不對等之僱傭系統的產生。

本文指出臺灣暫時性移工制度的政策目標，與平等勞動保護之間的矛盾關係。國境管制措施對於移工勞動條件的不利影響，許多是綿密但又隱而不見的，例如定期契約使移工勞動價值賤價化與彈性化、頻繁健康檢查涉移工隱私侵害、疾病歧視與工作剝奪等。但在平等保護的傳統操作之前，則看似根本不屬於勞動領域、或沒有相同處境的本國籍勞工可供比較，以確認有差別待遇的存在、乃至出於對國境管制決定的尊重而認為是合理正當的差別待遇。

本文重新反思人權法面對暫時性移工體制的挑戰，所要提醒的是，國境管制須與勞動平權的目的應相互衡平，而非一概國境優先。實則許多措施有可能在不過度妨國境管制所欲達成目標的前提下適當修正，使移工之勞工身分相對於外國人身分保持獨立、避免剝削性的僱傭系統。就臺灣的移工制度而言，例如：僱傭契約不以定期契約為必要、理性化健康檢查之要求、有期限的轉職限制、雇

主不負擔移工工作外的管理責任等等。換言之，讓國境管制就止步於國境，移工入境後應盡可能被納入一般勞動法、衛生防疫與僱傭管理的原則內，而非處於國境管制所創造的例外秩序之下。

這也意謂著對於何謂外國人平等之勞動保護，採取更為實質的理解，而這對本國勞工也是重要的。因為容許國境管制去創造次等的勞動力，會連帶拉低與移工同一就業市場的本國勞工之勞動條件。最終，以外國人之勞動平等為導向的國境管制，同時也就是保護本國勞工的勞動政策。

參考文獻

1. 中文部分

- 于宗先、王金利（2009），臺灣人口變動與經濟發展，臺北：聯經。
- 王素鸞、吳惠林（2001），外籍勞工在臺灣的趨勢、經濟關聯與政策，人口學刊，22期，頁49-70。
- 林良榮（2014），我國「外勞（客工）」的勞動人權與社會保障：兼論勞保條例之適用與檢討，台灣國際法季刊，11卷2期，頁51-86。
- 林佳和（2014），從國際人權的政治哲學觀談台灣的外國移工人權——兼論人權、勞動市場、產業競爭力的交錯與衝突，台灣國際法季刊，11卷2期，頁7-50。
- 林欣宜、魏嵩璽、蔡韶慧、張瓊文、黃婉婷、陳履烜、涂志宗、柯靜芬、林明誠（2013），外籍勞工結核病診斷及遣返作業之回顧——以中部地區為例，疫情報導，29卷8期，頁94-114。
- 邵允鍾（2007），從憲法角度檢視移工不得自由轉換雇主之相關規定：以平等權論述為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 徐揮彥（2006），從高捷泰勞事件淺論禁止強迫勞動相關國際人權規範之內涵及落實，台灣本土法學雜誌，83期，頁81-87。
- 張育菁、黃志傑、林詠青、吳麗琴、何麗莉、吳怡君（2017），1989-2015年臺灣受聘僱外國人健康檢查制度的演進與革新，疫情報導，33卷1期，頁9-16。
- 張昌吉（2002），外籍勞工對經濟、社會、政治層面影響之分析，政大勞動學報，12期，頁257-294。
- 張威儀（2012），臺灣勞動體制的剝削本質——歷史制度主義的觀

- 點，國立中山大學政治學研究所碩士論文。
- 許須美（1996），外勞與國內防疫問題，疫情報導，12卷11期，頁339-355。
- 彭雪玉（2006），國民黨政府勞動控制體制之探討：1949-1987年間歷史與結構的因素，思與言：人文與社會科學雜誌，44卷3期，頁179-230。
- 曾熾芬（2004），引進外籍勞工的國族政治，臺灣社會學刊，32期，頁1-58。
- 黃郁惠（2013），移工沉默的身體：分析台灣遣返結核病移工之醫療政策的權力意涵，南華大學應用社會學系碩士論文。
- 黃郁惠、齊偉先（2018），罹患肺結核的移工在台灣醫療照顧制度中的治療經驗與賦權，台灣公共衛生雜誌，37卷1期，頁63-76。
- 黃舒芃（2016），國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色：兼評司法院釋憲實務對國際及區域人權公約之看待與引用方式，臺灣民主季刊，13卷1期，頁85-129。
- 黃道明，陳柏旭譯（2012），台灣國家愛滋教育之國族身體形構與情感政治：以世界愛滋病日為線索，文化研究，15期，頁9-42。
- 劉士豪、羅國應（2010），批准「兩公約」對我國勞動法制之影響——論其與ILO公約及建議書之關係，台灣國際法季刊，7卷4期，頁5-46。
- 劉梅君（2000），「廉價外勞」論述的政治經濟學批判，台灣社會研究季刊，38期，頁59-90。
- 謝國雄（1994），勞動力是什麼樣的商品？計件制與台灣勞動者主體性之形塑，台灣社會研究季刊，17期，頁83-119。
- 鍾佩華、尤素芬、鄭雅文（2009），我國勞工健康檢查制度之現況與問題，台灣公共衛生雜誌，28卷2期，頁155-166。
- 藍佩嘉（2008），跨國灰姑娘：當東南亞幫傭遇上台灣新富家庭，

臺北：行人。

顧玉玲（2008），移工運動的主體形塑——以「家事服務法」推動過程為例，「台社二十週年會議：超克當前知識困境」學術研討會，台灣社會研究季刊社、世新大學台灣社會研究國際中心主辦，2008年9月27日。

——（2010），自由的條件：從越傭殺人案看台灣家務移工的處境，國立交通大學社會與文化研究所碩士論文。

——（2013），跛腳的偽自由市場：檢析台灣外勞政策的三大矛盾，台灣人權學刊，2卷2期，頁93-112。

2. 外文部分

Anderson, Bridget. 2010. Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers. *Work, Employment and Society* 24:300-317.

Bauder, Harald. 2006. *Labor Movement: How Migration Regulates Labor Markets*. New York, NY: Oxford University Press.

Bosniak, Linda. 2007. Being Here: Ethical Territoriality and the Rights of Immigrants. *Theoretical Inquiries in Law* 8:389-410.

———. 2010. Persons and Citizens in Constitutional Thought. *International Journal of Constitutional Law* 8:9-29.

Carens, Joseph. 2013. *The Ethics of Immigration*. Oxford: Oxford University Press.

Chetail, Vincent. 2019. *International Migration Law*. Oxford: Oxford University Press.

Cholewinski, Ryszard. 1997. *Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection in Countries of Employment*. Oxford: Clarendon Press.

———. 2006. International Labour Law and the Protection of Migrant Workers: Revitalizing the Agenda in the Era of Globalization. Pp.

- 409-444 in *Globalization and the Future of Labour Law*, edited by John D. R. Craig and S. Michael Lynk. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2007. The Human and Labor Rights of Migrants: Visions of Equality. *Georgetown Immigration Law Journal* 22:177-220.
- Collins, Hugh. 2010. *Employment Law*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.
- Collins, Hugh, Keith Ewing, and Aileen McColgan. 2012. *Labour Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collomp, Catherine. 2003. Labour Unions and the Nationalisation of Immigration Restriction in the United States, 1880-1924. Pp. 237-252 in *Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-war Period*, edited by Andreas Fahrmeir, Olivier Faron and Patrick Weil. Oxford: Berghahn Books.
- Craven, Matthew C. R. 1995. *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on Its Development*. Oxford: Clarendon Press.
- Crawford, James. 2002. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dauvergne, Catherine. 2004. Sovereignty, Migration and the Rule of Law in Global Times. *Modern Law Review* 67:588-615.
- Davidov, Guy. 2016. *A Purposive Approach to Labour Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Feldman, David. 2003. Was the Nineteenth Century a Golden Age for Immigrants? The Changing Articulation of National, Local and Voluntary Controls. Pp. 167-177 in *Migration Control in the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the*

- United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, edited by Andreas Fahrmeir, Olivier Faron and Patrick Weil. Oxford: Berghahn Books.
- Fudge, Judy. 2012. Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of International Rights for Migrant Workers. *Comparative Labor Law and Policy Journal* 34:95-132.
- Guchteneire, Paul De, and Antoine Pécoud. 2009. Introduction: The UN Convention on Migrant Workers' Rights. Pp. 1-43 in *Migration and Human Rights: the United Nations Convention on Migrant Workers' Rights*, edited by Ryszard Cholewinski, Paul De Guchteneire and Antoine Pécoud. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kahn-Freund, Otto. 1983. *Kahn-Freund's Labour and the Law*. 3d ed., edited by Paul Davies and Mark Freedland. London: Stevens and Sons.
- Kuwahara, Yasuo. 2005. Migrant Workers in the Post-War History of Japan. *Japan Labor Review* 2(4):25-47.
- Lake, Marilyn, and Henry Reynolds. 2008. *Drawing the Global Colour Line: White Men's Countries and the International Challenge of Racial Equality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lu, Haina. 2008. The Personal Application of the Right to Work in the Age of Migration. *Netherlands Quarterly of Human Rights* 26:43-77.
- Lucassen, Leo. 1998. The Great War and the Origins of Migration Control in Western Europe and the United States (1880-1920). Pp. 45-72 in *Regulation of Migration: International Experiences*, edited by Anita Böcker, Kees Groenendijk, Tetty Havinga and Paul Minderhoud. Amsterdam: Het Spinhuis.
- Mantouvalou, Virginia. 2008. Human Rights and Unfair Dismissal:

- Private Acts in Public Spaces. *Modern Law Review* 71:912-939.
- McKeown, Adam M. 2011. *Melancholy Order: Asian Migration and the Globalization of Borders*. 2d ed. New York, NY: Columbia University Press.
- Mezzadra, Sandro, and Brett Neilson. 2013. *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*. Durham: Duke University Press.
- Miles, Robert. 1987. *Capitalism and Unfree Labour: Anomaly or Necessity?*. London: Tavistock Publications Ltd.
- Miller, David. 2016. *Strangers in Our Midst*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Motomura, Hiroshi. 2008. The Rule of Law in Immigration Law. *Tulsa Journal of Comparative and International Law* 15:139-153.
- Nielsen, Henrik Karl. 1994. The Concept of Discrimination in Ilo Convention No.111. *International and Comparative Law Quarterly* 43:827-856.
- Olney, Shauna and Ryszard Cholewinski. 2014. Migrant Workers and the Right to Non-Discrimination and Equality. Pp. 259-281 in *Migrants at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law*, edited by Cathryn Costello and Mark Freedland. Oxford: Oxford University Press.
- Perruchoud, Richard. 2012. State Sovereignty and Freedom of Movement. Pp. 123-151 in *Foundations of International Migration Law*, edited by Brian Opeskin, Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruhs, Martin. 2006. The Potential of Temporary Migration Programmes in Future International Migration Policy. *International Labour Review* 145:7-36.
- . 2013. *The Price of Rights: Regulating International Labor Migration*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- . 2014. Immigration and Labour Market Protectionism: Protecting Local Workers' Preferential Access to the National Labour Market. Pp. 60-78 in *Migrants at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law*, edited by Cathryn Costello and Mark Freedland. Oxford: Oxford University Press.
- . 2016. Protecting the Rights of Temporary Migrant Workers: Ideals versus Reality. Pp. 299-325 in *Temporary Labour Migration in the Global Era: The Regulatory Challenges*, edited by Joanna Howe and Rosemary Owens. London: Bloomsbury Publishing.
- Ryan, Bernard, and Virginia Mantouvalou. 2014. The Labour and Social Rights of Migrants in International Law. Pp. 177-211 in *Human Rights and Immigration*, edited by Ruth Rubio-Marín. Oxford: Oxford University Press.
- Saul, Ben, David Kinley, and Jaqueline Mowbray. 2014. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases, and Materials*. Oxford: Oxford University Press.
- Sepúlveda, M. Magdalena. 2003. *The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Antwerpen: Intersentia.
- Sharma, Nandita. 2006. *Home Economics: Nationalism and the Making of "Migrant Workers" in Canada*. Toronto: University of Toronto Press.
- Sivakumaran, Sandesh. 2009. Impact on the Structure of International Obligations. Pp. 133-50 in *The Impact of Human Rights Law on General International Law*, edited by Menno T. Kamminga and Martin Scheinin. Oxford: Oxford University Press.
- Ssenyonjo, Manisuli. 2016. *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*. 2d ed. London: Bloomsbury Publishing.

- Thomas, Chantal. 2011. Convergences and Divergences in International Legal Norms on Migrant Labor. *Comparative Labor Law and Policy Journal* 32:405-442.
- Torpey, John C. 2018. *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*. 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wachter, Michael L. 1974. Primary and Secondary Labor Markets: A Critique of the Dual Approach. *Brookings Papers on Economic Activity* 1974:637-694.
- Weissbrodt, David S. 2008. *The Human Rights of Non-Citizens*. Oxford: Oxford University Press.
- Yang, Ya-Wen. 2019. Towards Democratic Citizenship for Temporary Migrant Workers: A Non-Domination Approach. Ph.D. Dissertation. SOAS University of London, London.

Can Equal Protection for Workers as an International Human Right Transcend State Borders?:

The Hard Case of the Temporary Migrant Worker Programme in Taiwan

*Ya-Wen Yang**

Abstract

Taking Taiwan's temporary migrant worker (TMW) programme as an example, this article investigates the dilemma that TMW programmes impose on foreign worker's human right to employment equality. TMWs have dual identities of workers and foreigners. Being workers, they are entitled to equality to and at work without prejudice to nationality under the international human rights law; whereas being foreigners, they are subject to border controls which condition their entry, stay and access to the labour market of the receiving state. The international human rights doctrine on employment equality is generally deferential to the border regime. However, an irreconcilable tension emerges when border controls that constitute key characteristics of the TMW programme adversely affect TMWs' working conditions. At this juncture, shall the human rights law insist on equal working conditions, emphasising on TMWs' being workers; or defer to border controls, focusing on their being foreigners? This article first examines the doctrine of foreigners' equal right to and at work. It then demonstrates how such a tension prevents the equal protection law from addressing gross employment discrimination against TMWs in the four aspects of Taiwan's TMW programme, namely (1) forced rotation, (2) frequent health checks, (3)

* Post-Doctoral Scholar, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

deprivation of employment mobility and (4) monitoring workers' whereabouts. It concludes by proposing a balancing approach which better accommodates TMWs' equal rights at work under the border regime.

KEYWORDS: migrant workers, guest workers, the right to work, rights at work, equal protection, ICESCR (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ICPRMW (the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), ILO (International Labour Organization), border control.